



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 04

Der Unternehmer und das Unternehmen

10

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	DER UNTERNEHMER UND DAS UNTERNEHMEN	1
1.	Der Begriff des Unternehmers und seine Bedeutung	1
1.1	Die Bedeutung des Unternehmerbegriffs im UStG	1
1.2	Die Eigenständigkeit des umsatzsteuerlichen Unternehmerbegriffs	2
2.	Die Voraussetzungen der Unternehmereigenschaft	2
3.	Die Unternehmerfähigkeit	3
3.1	Natürliche Personen	4
3.2	Juristische Personen des privaten Rechts als Unternehmer	4
3.3	Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts als Unternehmer	4
3.3.1	Rechtslage bis 31.12.2016 (§ 2 Abs. 3 UStG und Abschn. 2.11 UStAE)	5
3.3.2	Gesetzliche Neuregelung ab 1.1.2017 (§ 2b UStG nF.)	5
3.4	Personenzusammenschlüsse als Unternehmer	6
3.4.1	Innengesellschaften	8
3.4.2	Beispiele für Personenvereinigungen und unternehmerische Unternehmenszusammenschlüsse	8
4.	Selbständigkeit	11
4.1	Selbständigkeit oder Unselbständigkeit natürlicher Personen	11
4.2	Unselbständigkeit juristischer Personen bzw. von Personengesellschaften (Organschaft)	13
4.2.1	Die Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft	13
4.2.2	Beginn und Ende der Organschaft	18
4.2.3	Die Wirkungen der Organschaft	18
4.2.4	Keine grenzüberschreitende Wirkung der Organschaft	19
5.	Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit	19
5.1	Allgemeines	20
5.2	Tätigkeit im wirtschaftlichen Sinne als Voraussetzung der Unternehmereigenschaft	20
5.2.1	Leistungen im wirtschaftlichen Sinne	20
5.2.2	Holdinggesellschaften	21
5.2.3	Nichtunternehmerische Tätigkeiten	21
5.3	Nachhaltigkeit	22
6.	Erzielung von Einnahmen	23



7.	Beginn und Ende der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit	23
7.1	Beginn der Unternehmertätigkeit	23
7.1.1	Unternehmereigenschaft aufgrund von Vorbereitungshandlungen	23
7.1.2	Beginn der Unternehmereigenschaft einer Kapitalgesellschaft	24
7.1.3	Beginn der Unternehmereigenschaft einer Personengesellschaft	26
7.2	Ende der Unternehmereigenschaft	26
8.	Das Unternehmen	27
8.1	Begriff und Bedeutung	27
8.2	Der unternehmerische und der nichtunternehmerische Tätigkeitsbereich	28
9.	Der Verein als Unternehmer	29
10.	Kleinunternehmerschaft	29
II.	ÜBUNGSFALL	30
1.	Sachverhalt	30
2.	Aufgabe	30
3.	Lösung	31

I. DER UNTERNEHMER UND DAS UNTERNEHMEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 04 – Überblick – v10415

1. Der Begriff des Unternehmers und seine Bedeutung

1.1 Die Bedeutung des Unternehmerbegriffs im UStG

Die Umsatzsteuer zählt zwar nach ihrer finanzwissenschaftlichen Zuordnung zu den Personensteuern, das UStG verwendet jedoch den bei personenbezogenen Steuern üblichen Begriff des „Steuerpflichtigen“ nicht (im Gegensatz zur Mehrwertsteuersystem-Richtlinie). Steuerpflichtig sind bei der USt keine Personen, sondern steuerbare Verkehrsvorgänge (Lieferungen und sonstige Leistungen, entgeltlichen Leistungen gleichgestellte Leistungsentnahmen zu nichtunternehmerischen Zwecken, innergemeinschaftliche Erwerbe, Einfuhren). Jedoch kommt der Steuergläubiger auch bei den Verkehrssteuern nicht ohne eine Person aus, bei der die Steuer erhoben wird. Die Funktion dieses Steuersubjekts erfüllt bei der USt der Unternehmer.



PRÜFUNGSTIPP

In der Umsatzsteuerklausur müssen Sie nur dann näher auf die Unternehmereigenschaft einer Person eingehen, wenn Sie entweder

- *in der Aufgabenstellung dazu aufgerufen sind (wie zB. in der Steuerberaterprüfung 2020: „Gehen Sie kurz auf die Unternehmereigenschaft und den Umfang des Unternehmens von XXX ein.“ oder in der Steuerberaterprüfung 2024: „Nehmen Sie zur Unternehmereigenschaft und dem Umfang des Unternehmens von XXX Stellung.“) oder*
- *die Unternehmereigenschaft in der Klausur zum Problem wird (zB. beim Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 UStG, der nur möglich ist, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird).*
- *In der Steuerberaterprüfung 2019 wurde in der Aufgabenstellung ausdrücklich auf Ausführungen zur Unternehmereigenschaft und zum Umfang des Unternehmens verzichtet.*

Das **Tatbestandsmerkmal „Unternehmer“** ist einer der zentralen Begriffe der Umsatzsteuer:

- **steuerbare Umsätze** iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 5 UStG können nur Unternehmer tätigen;
- die Bestimmung des **Leistungsorts** nach § 3a Abs. 2 UStG richtet sich danach, ob der Leistungsempfänger Unternehmer ist;
- einen **Verzicht auf eine Steuerbefreiung** nach § 9 UStG kann nur ein Unternehmer bei einem Umsatz an einen anderen Unternehmer wirksam erklären;
- grundsätzlich kann die Steuerschuld nach **§ 13b UStG** nur auf einen Unternehmer übergehen;
- nur Unternehmer sind nach § 15 UStG zum **Vorsteuerabzug** berechtigt;
- als **Vorsteuer abziehbar** ist nur die von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte USt.



PRÜFUNGSTIPP

In den vergangenen Jahren wurden die Prüfungskandidaten in der USt-Klausur der Steuerberaterprüfung häufig aufgefordert, „kurz auf die Unternehmereigenschaft und den Umfang des Unternehmens“ des jeweiligen Protagonisten einzugehen, und zwar: 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013. In der Prüfung des Jahres 2023 war ausdrücklich keine Stellungnahme gefordert. Im Jahr 2024 war hierzu wieder Stellung zu nehmen.



1.2 Die Eigenständigkeit des umsatzsteuerlichen Unternehmerbegriffs



HINWEIS

Die Definition des umsatzsteuerlichen Unternehmerbegriffs: „Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt“, dh. nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen tätig ist (§ 2 Abs. 1 UStG), ist weiter gespannt als der Unternehmerbegriff des **Gewerbe- und Einkommensteuerrechts**, da Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr und Gewinnerzielungsabsicht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG, § 15 Abs. 2 EStG) nicht erforderlich sind.

▶ Fallbeispiel:

Die Finanzbeamtin Daniela Keller erwirbt am 1.7. als Vermögensanlage eine Eigentumswohnung für 150.000 €, die sie ab 1.8. an den angestellten Steuerberater Dr. Eduard Forster vermietet.

▶ Lösung:

Daniela Keller ist umsatzsteuerliche Unternehmerin iSv. § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG, da sie eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Die Vermietung ist eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen (§ 2 Abs. 1 Satz 3 UStG). § 2 Abs. 1 UStG kennt – anders als der Gewerbebetriebsbegriff des § 15 Abs. 2 EStG – das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal „keine private Vermögensverwaltung“ nicht.

Dass die Vermietung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei ist, ändert nichts an der Unternehmereigenschaft von Daniela Keller.

Der umsatzsteuerliche Unternehmerbegriff weicht auch völlig vom Sprachgebrauch des täglichen Lebens ab: Im Unterschied zur Alltagssprache sind für die Umsatzsteuer auch der Arzt, der Künstler, der Berufssportler, der schriftstellernde Richter usw. Unternehmer. Die Unternehmereigenschaft iSd. UStG setzt demnach nur eine **wirtschaftliche Tätigkeit** voraus, die zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen unternommen wird. Keine Voraussetzung für die Unternehmereigenschaft ist, dass der Unternehmer ein Unternehmensvermögen besitzt.

Der **Unternehmerbegriff** des UStG setzt voraus:

- eine **unternehmerfähige** Person (natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigungen) als Subjekt der Umsatzsteuerpflicht,
- die **Selbständigkeit** dieser Person/Personenvereinigung,
- die Ausübung einer **gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit**.

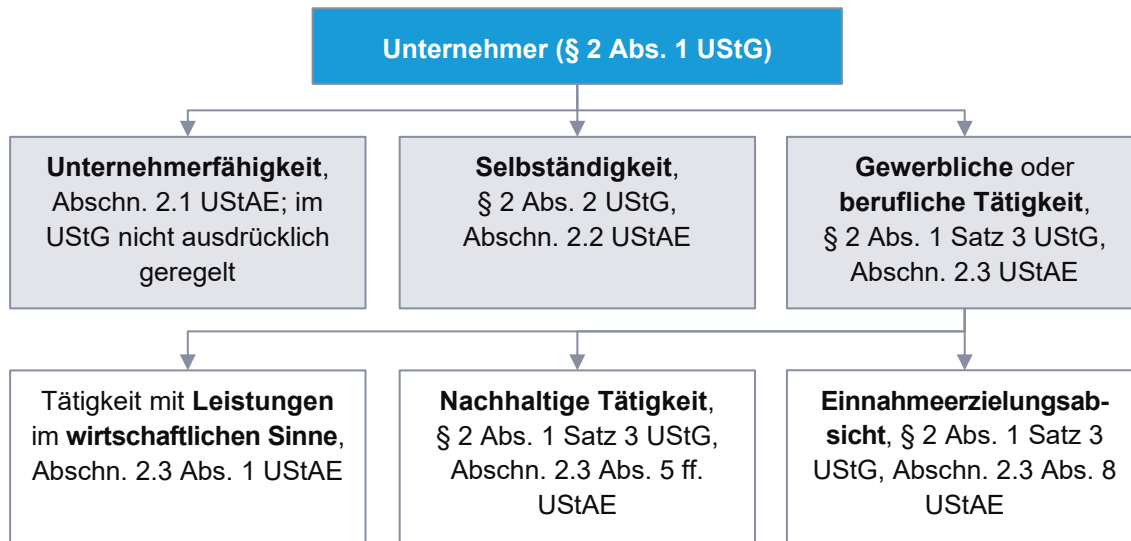
2. Die Voraussetzungen der Unternehmereigenschaft



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unternehmerbegriff – v10276

Die **Voraussetzungen**, von denen die Umsatzsteuer die **Unternehmereigenschaft** abhängig macht, stellen sich wie folgt dar:



3. Die Unternehmerfähigkeit

Die Fähigkeit, Träger umsatzsteuerlicher Rechte und Pflichten zu sein (Unternehmer), deckt sich nicht zwingend mit der Rechtsfähigkeit im zivilrechtlichen Sinne. Die Unternehmerfähigkeit geht teilweise weiter als die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit. Die Unternehmerfähigkeit setzt eine gewerbliche oder berufliche Selbständigkeit voraus, hingegen nicht zwingend auch eine rechtliche Selbständigkeit. Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinn ist demnach grundsätzlich **jedes selbständig tätige Wirtschaftsgebilde, das nachhaltig Leistungen gegen Entgelt ausführt**. Danach ist Unternehmer auch noch eine GmbH, die wegen Vermögenslosigkeit im Handelsregister gelöscht wurde und daher auch als Liquidationsgesellschaft nicht mehr in Erscheinung tritt (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 8 UStAE).

Da Objekt der USt grundsätzlich die **wirtschaftliche Leistung** ist und durch Überwälzung der USt eine allgemeine Verbrauchsbesteuerung erreicht werden soll, kann es auf die Rechtsform desjenigen, der die Leistung erbringt, nicht ankommen. Einen Unternehmer kraft Rechtsform kennt das UStG nicht (Abschn. 2.1 Abs. 1 Satz 3 UStAE). Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG können sein (Abschn. 2.1 Abs. 1 Satz 1 UStAE): **natürliche Personen, juristische Personen und Personenzusammenschlüsse**.



HINWEIS

Der BFH hat mit Urteil vom 22.11.2018 (Az. V R 65/17) und auch in seiner nachfolgenden Rechtsprechung entschieden, dass die Unternehmerfähigkeit eine zivilrechtliche Rechtsfähigkeit voraussetzt. Unternehmer können nur die hinter einer Bruchteilsgemeinschaft stehenden Gemeinschaftler sein, denen Eingangs- und Ausgangsleistungen anteilig zuzurechnen sind. Mit Wirkung zum 1.1.2023 hat der Gesetzgeber § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG geändert und die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit ausdrücklich für unerheblich im Umsatzsteuerrecht erklärt. Nichtsdestotrotz bleibt der BFH bei seiner ablehnenden Rechtsauffassung. Für die Prüfung folgen Sie dennoch der gesetzlichen Regelung, die sich auch in der Auffassung der Finanzverwaltung in Abschn. 2.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE widerspiegelt.



3.1 Natürliche Personen

Die Mehrzahl der Unternehmer ist als natürliche Person ein **Einzelunternehmer** (Gewerbetreibender, Freiberufler, Vermieter usw.).

Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die natürliche Person im zivilrechtlichen Sinne geschäftsfähig ist. Eine **beschränkt geschäftsfähige** (§ 106 BGB) oder eine **geschäftsunfähige** (§ 104 BGB) Person ist als Inhaber eines Unternehmens Unternehmer; das Unternehmen wird ggf. von ihrem gesetzlichen Vertreter oder von einem von diesem beauftragten Dritten betrieben.

► **Fallbeispiel:**

Der zweijährige Volker Reich ist Alleinerbe des Anfang Januar tödlich verunglückten Armin Reich. Zum Nachlass gehört ua. die Maschinenfabrik Gebr. Reich, deren Alleininhaber Armin Reich war. Das Unternehmen wird nach testamentarischer Verfügung des Erblassers bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres des Erben vom Geschäftsführer Carl Streng geführt.

► **Lösung:**

Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG ist der zweijährige Volker Reich. Für die Unternehmereigenschaft ist nicht entscheidend, wer tätig wird, sondern in wessen Namen eine unternehmerische Tätigkeit ausgeübt wird (Abschn. 2.1 Abs. 3 Satz 4 UStAE).

Die Umsatzsteuer kennt im Unterschied zur Einkommensteuer **keine Zusammenveranlagung**. Sind Ehemann und Ehefrau aufgrund jeweils eigener Tätigkeit Unternehmer, so werden sie unabhängig voneinander zur Umsatzsteuer veranlagt.

Der **Insolvenzverwalter** wird als gesetzlicher Vertreter des Schuldners tätig; der Schuldner bleibt trotz des auf den Insolvenzverwalter übergegangenen Verwaltungs- und Verfügungsrechts Unternehmer hinsichtlich aller Leistungen, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter veranlasst werden. Der Schuldner bleibt Rechtsträger und damit leistender Unternehmer (Abschn. 2.1 Abs. 7 Satz 1 UStAE).

3.2 Juristische Personen des privaten Rechts als Unternehmer

Juristische Personen des privaten Rechts sind AG, KGaA, GmbH, Genossenschaften (eG.), eingetragene Vereine (eV.). Umsatzsteuerliche Unternehmer sind sie, wenn sie durch wirtschaftliche Leistungen nach außen erkennbar als Personenvereinigung auftreten. Bei Gesellschaften des Handelsrechts spricht die Vermutung für das Vorliegen einer gewerblichen Tätigkeit und damit für die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft.

3.3 Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts als Unternehmer

Unter juristischen Personen des öffentlichen Rechts (**JPöR**) sind Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zu verstehen, denen vom Staat Rechtspersönlichkeit verliehen ist. Dazu zählen (Abschn. 2.11 Abs. 1 UStAE) zB.:

- Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände)
- öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften
- Steuerberaterkammern, Rechtsanwaltskammern
- Handwerkskammern, Handwerksinnungen
- Industrie- und Handelskammern (IHK).

Über ihre eigentlichen hoheitlichen Aufgaben hinaus beteiligt sich die öffentliche Hand in vielfältiger Weise am wirtschaftlichen Leben und tritt so in **Konkurrenz zu privatrechtlichen Unternehmern**, die entsprechende Leistungen anbieten. Gleichzeitig drängen auf der anderen Seite immer mehr **private Unternehmer** auf den Markt der „öffentlichen Daseinsfürsorge“ und treten so in Konkurrenz zur öffentlichen Hand.



HINWEIS

Die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts war nach § 2 Abs. 3 UStG idF. bis 31.12.2016 von einer Tätigkeit im Rahmen eines ertragsteuerlichen Betriebs gewerblicher Art abhängig, was gegen Unionsrecht verstieß. Infolgedessen hatte der Gesetzgeber mit Wirkung ab 1.1.2017 eine Neuregelung durch § 2b UStG erlassen. Den juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde jedoch die Möglichkeit eingeräumt, einen Antrag auf Fortgeltung der Regelung bis 31.12.2016 bis 31.12.2020 zu stellen. Sofern ein Antrag gestellt wurde, wurde die Übergangsfrist immer wieder verlängert. Derzeit gilt sie noch bis 31.12.2026. Nachfolgend werden beide Regelungen in ihren Grundzügen dargestellt.

3.3.1 Rechtslage bis 31.12.2016 (§ 2 Abs. 3 UStG und Abschn. 2.11 UStAE)

JPöR wurden gem. § 2 Abs. 3 UStG grundsätzlich nur **im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art** (BgA) iSv. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG, § 4 KStG und ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig (Abschn. 2.11 Abs. 2 UStAE). Darüber hinaus galten stets als unternehmerisch die in § 2 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2–5 UStG genannten Tätigkeiten der JPöR. Die Gesamtheit aller Betriebe gewerblicher Art und aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sowie die Tätigkeitsbereiche, die nach § 2 Abs. 3 Satz 2 UStG als unternehmerische Tätigkeiten gelten, stellten das Unternehmen der JPöR dar. Nur die in diesen Betrieben und Tätigkeitsbereichen ausgeführten Umsätze waren steuerbar.

Nichtunternehmerisch tätig war die JPöR im Bereich **ihrer hoheitlichen Tätigkeiten**, dh. bei der Ausübung öffentlicher Gewalt. Der hoheitliche Bereich der JPöR stellte die negative Abgrenzung gegenüber den Betrieben gewerblicher Art dar (§ 4 Abs. 5 KStG). Hoheitsbetriebe waren nach der Legaldefinition des § 4 Abs. 5 KStG solche, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen.

3.3.2 Gesetzliche Neuregelung ab 1.1.2017 (§ 2b UStG nF.)

Das Steueränderungsgesetz 2015 hat **mit Wirkung zum 1.1.2017** § 2 Abs. 3 UStG aufgehoben und § 2b UStG eingeführt. Hierdurch hat der Gesetzgeber die Gesetzeslage für die Besteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts an die Rechtsprechung des BFH angeglichen und den Bezug zum KStG aufgehoben.

Eine JPöR ist trotz einer wirtschaftlichen Tätigkeit gem. § 2b Abs. 1 UStG nicht als Unternehmer tätig, wenn sie **öffentliche Gewalt** ausübt und ihre Behandlung als Nichtunternehmer **nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen** führt. Wenn diese beiden Voraussetzungen vorliegen, ist eine JPöR nicht als Unternehmer tätig und ihre Leistungen sind nicht umsatzsteuerbar. § 2b Abs. 2 und Abs. 3 UStG nennen beispielhaft Fälle, in denen keine größeren Wettbewerbsverzerrungen bestehen.

3.3.2.1 Öffentliche Gewalt

Eine JPöR übt keine öffentliche Gewalt aus, soweit sie **auf privatrechtlicher Grundlage** (zB. zivilrechtlicher Vertrag) tätig ist. Ist eine JPöR jedoch **auf öffentlich-rechtlicher Grundlage** tätig, übt sie öffentliche Gewalt aus. Öffentlich-rechtliche Handlungsgrundlagen sind zB. Verwaltungsakte, öffentlich-rechtliche Verträge oder Satzungen. Das bedeutet: Sobald eine JPöR auf privatrechtlicher Grundlage Leistungen erbringt, ist sie als Unternehmer tätig.

Nur wenn die JPöR auf öffentlich-rechtlicher Grundlage leistet, kann die Ausnahmeregelung des § 2b UStG mit der Folge der nichtunternehmerischen Tätigkeit anwendbar sein (sofern die JPöR nicht in größeren Wettbewerb zu privaten Dritten tritt). Der Handlungsgrundlage der Tätigkeit einer JPöR kommt daher nach § 2b UStG entscheidende Bedeutung zu. Ob die JPöR im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA, vgl. § 2 Abs. 3 UStG aF.) handelt, ist nicht mehr relevant.



Die Anknüpfung an das Körperschaftsteuerrecht (vgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG aF. iVm. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG, § 4 KStG) ist passé.

3.3.2.2 Größere Wettbewerbsverzerrungen

Generell liegt kein größerer Wettbewerb zu privaten Wirtschaftsteilnehmern vor, wenn kein privater Wettbewerber Leistungen erbringen kann, die mit den Leistungen der jPöR vergleichbar wären. § 2b Abs. 2 UStG regelt, dass insbesondere dann kein Wettbewerb vorliegt, wenn die jPöR aus gleichartigen Tätigkeiten im Kalenderjahr **weniger als 17.500 € Umsatz** erzielt oder vergleichbare, auf privat-rechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne Recht auf Verzicht gem. § 9 UStG einer **Steuerbefreiung** unterliegen.

In § 2b Abs. 3 UStG versucht der Gesetzgeber, auch weiterhin den Leistungsaustausch zwischen zwei jPöR (zB. interkommunale Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit zweier kirchlicher Rechtsträger) von der Besteuerung auszunehmen. Denn bisher lag bei **sog. Beistandsleistungen** kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) vor. Die Leistungen wurden als nicht steuerbar behandelt. Auch zukünftig soll eine Ausnahme gelten, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen: So besteht nach dem neuen Gesetz kein Wettbewerb,

- wenn Leistungen auf Grundlage einer langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erbracht werden,
- sie dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,
- sie ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
- die leistende jPöR gleichartige Leistungen im Wesentlichen nur an andere jPöR erbringt.

Diese Ausnahme kann nur greifen, wenn aufgrund der Handlungsgrundlage feststeht, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden jPöR in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, also auf öffentlich-rechtlicher Grundlage stattfindet.

3.3.2.3 Übergangsregelung

Gemäß § 27 Abs. 22, 22a UStG ist die Neuregelung auf alle Leistungen ab dem 1.1.2017 anzuwenden. Die jPöR konnte allerdings bis zum 31.12.2016 gegenüber dem Finanzamt erklären, dass sie die Neuregelung erst später anwenden möchte. Die Frist zur spätestens Anwendung wurde mehrmals geändert und zuletzt durch das Jahressteuergesetz 2024 auf den 1.1.2027 verlängert. Die Erklärung gilt einheitlich für den gesamten unternehmerischen Bereich der jPöR. Die jPöR kann die Erklärung allerdings jeweils zu Beginn des folgenden Kalenderjahres widerrufen.



PRÜFUNGSTIPP

Aufgrund dem Nebeneinander zweierlei Regelungen ist wohl nicht davon auszugehen, dass eine jPdöR zum Prüfungsgegenstand gemacht wird. Jedoch sollten die Grundzüge bekannt sein, wenn beispielsweise die Auswirkungen einer Vermietung an eine jPdöR zu prüfen sind. Denn insoweit ist bei nichtunternehmerischer (meist hoheitlicher) Nutzung eine Option zur Steuerpflicht, mangels Leistung an einen anderen Unternehmer, ausgeschlossen.

3.4 Personenzusammenschlüsse als Unternehmer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zusammenschlüsse als Unternehmer – v10322

Unternehmer können auch Personenzusammenschlüsse sein, sofern sie **nach außen** in Erscheinung treten, dh. gegenüber dem Leistungsempfänger als **Schuldner der Leistung** auftreten. Es genügt ein Mindestmaß an Organisation, das die Personenvereinigung befähigt, als solche (Gesellschaft, Gemeinschaft, nicht rechtsfähiger Verein usw.) nach außen aufzutreten.

Ein Auftreten nach außen setzt jedoch nicht voraus, dass die Personenvereinigung gegenüber dritten Personen Leistungen erbringt. Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 UStG wird dieses Merkmal auch dann erfüllt, wenn eine Personenvereinigung **nur gegenüber ihren Mitgliedern** tätig wird.

► **Fallbeispiel:**

Vier freiberuflich tätige Ärzte haben eine Apparategemeinschaft gegründet, die medizinische Einrichtungen, Apparate und Geräte zentral beschafft und den Mitgliedern der Gemeinschaft für ihre Arztpraxen zur Verfügung stellt. Die Gemeinschaft führt mit eigenem medizinisch-technischem Personal für die Praxen ihrer Mitglieder Laboruntersuchungen, Röntgenaufnahmen und andere medizinisch-technische Leistungen aus. Der für das Personal, die Geräte und die Räumlichkeiten erforderliche Aufwand wird von den Ärzten nach dem Umfang ihrer Inanspruchnahme der Gemeinschaftseinrichtungen getragen.

► **Lösung:**

Die Apparategemeinschaft tätigt keine Umsätze mit Außenstehenden; sie tritt lediglich als Leistungsempfängerin bei der Anschaffung von Geräten und der Anmietung von Räumlichkeiten sowie bei der Anstellung von Personal nach außen hervor. Sie erbringt jedoch gegenüber ihren Mitgliedern entgeltliche Leistungen, was ihre Unternehmereigenschaft begründet. Die steuerbaren sonstigen Leistungen sind grds. nach § 4 Nr. 29 UStG steuerfrei.

Personenzusammenschlüsse, die Unternehmer iSd. UStG sein können, sind insbesondere:

- Personengesellschaften des Handelsrechts (OHG, KG),
- Partnerschaftsgesellschaften,
- Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, zB. Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe (ARGE – Abschn. 1.6 Abs. 8 UStAE), Sozietäten, Apparategemeinschaften ua.,
- Bruchteilsgemeinschaften (§§ 741 ff. BGB), nichtrechtsfähige Vereine, Erbengemeinschaften, Grundstücksgemeinschaften, Wohnungseigentümergeinschaften (Abschn. 2.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE).

Die vielfältigen Erfordernisse des Wirtschaftslebens führen dazu, dass sich Unternehmer – Einzelpersonen oder Gesellschaften – zu besonderen Gebilden unterschiedlicher Rechtsformen zusammenschließen, um gemeinsam wirtschaftliche Tätigkeiten zu unternehmen. Um solche Unternehmenszusammenschlüsse, die regelmäßig durch vertragliche Vereinbarungen entstehen, handelt es sich bei

- Ein- und Verkaufsgemeinschaften, Absatzgenossenschaften,
- Arbeitsgemeinschaften von Handwerkern, Gewinngemeinschaften,
- Interessengemeinschaften, Kartelle, Konzerne, Konsortien usw.

Bei solchen Zusammenschlüssen stellt sich die Frage, inwieweit das neu entstandene Gebilde selbst **Unternehmereigenschaft** besitzt, welche umsatzsteuerliche Stellung die einzelnen Mitglieder im Verhältnis zu dem Zusammenschluss haben und ob und inwieweit die einzelnen Mitglieder nach außen selbständige Unternehmer geblieben sind.



Solche Zusammenschlüsse können

- **Innengesellschaften** sein, bei denen die Beteiligten Unternehmer bleiben und die Innengesellschaft als solche nicht Unternehmerin ist (zB. Einkaufsring),
- als **Unternehmer** in Erscheinung treten, wobei die Beteiligten neben dem als Unternehmer tätigen Zusammenschluss als Einzelpersonen selbständig tätig sind und damit daneben Unternehmer bleiben (zB. die Apparategemeinschaft, siehe vorstehender Übungsfall), oder
- als **Unternehmer** in Erscheinung treten, wobei die Beteiligten in der Gemeinschaft aufgehen (zB. Sozietät mehrerer Rechtsanwälte und/oder Steuerberater).

3.4.1 Innengesellschaften

Eine Personenvereinigung oder ein Unternehmerzusammenschluss hat dann keine Unternehmereigenschaft, wenn die Vereinigung selbst keine Leistungen iSd. UStG erbringt und deshalb auch nach außen gar nicht in Erscheinung tritt, sondern lediglich die gemeinsamen Interessen der Mitglieder wahrnimmt. Es handelt sich dabei um sog. Innengesellschaften. Sie sind, wie der Name schon sagt, dadurch gekennzeichnet, dass das Gesellschaftsverhältnis nach außen nicht hervortritt. Sie sind umsatzsteuerlich unbeachtlich (Abschn. 2.1 Abs. 5 Satz 1 UStAE).

Prototyp der Innengesellschaft ist die **stille Gesellschaft** iSd. § 230 HGB. Der stille Gesellschafter hat seine Vermögenseinlage „so zu leisten, dass sie in das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts übergeht“; es wird also kein Gesamthandsvermögen gebildet. Die stille Gesellschaft tritt handelnd nach außen nicht hervor. Nur der Inhaber des Handelsgeschäfts wird aus den in dem Betrieb ausgeführten Geschäften berechtigt und verpflichtet (§ 230 Abs. 2 HGB), sein Unternehmen stellt unverändert ein Einzelhandelsgeschäft dar. Eine umsatzsteuerlich unbeachtliche Innengesellschaft liegt sowohl bei der typischen wie auch bei der atypischen stillen Gesellschaft vor; die ertragsteuerlich relevante Unterscheidung in typische und atypische stille Gesellschaft spielt in der Umsatzsteuer daher keine Rolle (Abschn. 2.1 Abs. 5 Satz 3 UStAE).

3.4.2 Beispiele für Personenvereinigungen und unternehmerische Unternehmenszusammenschlüsse

Ein Unternehmenszusammenschluss ist als Personenvereinigung **Unternehmer** iSd. § 2 Abs. 1 UStG, wenn er als solcher Leistungen erbringt und damit als gesellschaftsrechtliches Gebilde **nach außen auftritt**. Auftreten nach außen ist auch gegeben, wenn einer der Beteiligten sich im Namen des Zusammenschlusses gewerblich oder beruflich betätigt.

3.4.2.1 Bürogemeinschaften

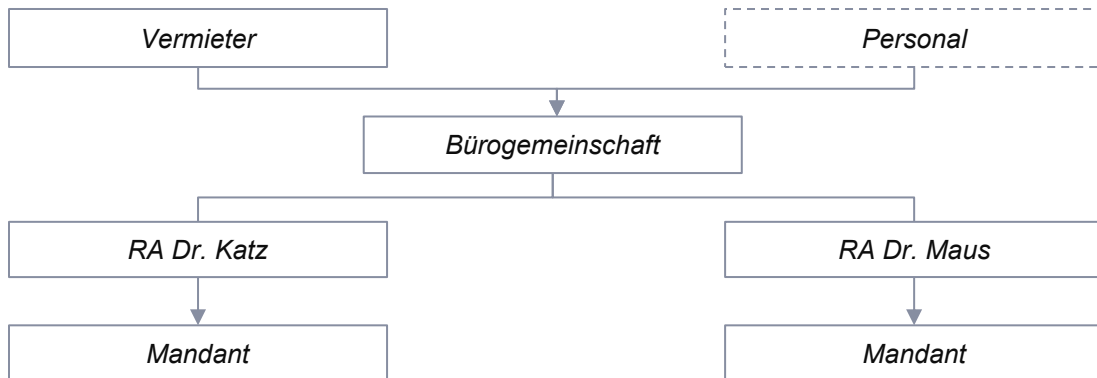
Die Bürogemeinschaft, zB. von Rechtsanwälten, als solche (im Gegensatz zu einer Sozietät) führt keine steuerbaren Leistungen aus, wenn sich die Anwälte nur zur Verteilung und **anteiligen Übernahme von Kosten** zusammenfinden. In seiner Anwaltstätigkeit bleibt jeder Anwalt selbständig. Auch wenn die Bürogemeinschaft keine Umsätze mit Außenstehenden tätigt, wird sie steuerlich als Außengesellschaft angesehen, wenn sie in sonstiger Weise (zB. bei der Anstellung von Personal, bei der Miete von Räumlichkeiten usw.) nach außen auftritt.

► **Fallbeispiel:**

Die Rechtsanwälte Dr. Katz und Dr. Maus kommen überein, zur Minimierung der Kosten ihrer Bürobetriebe Personal und Kanzleieinrichtungen gemeinsam zu unterhalten. Ab 1.1. betreiben sie ihre Kanzlei in Mieträumen, die den unmittelbaren Zugang von einer Kanzlei zur anderen ermöglichen. Sie beschäftigen nur noch eine Telefonistin, auch die Schreibkräfte arbeiten jeweils nach Bedarf für den einen oder anderen Anwalt. Miet- und Arbeitsverträge lauten auf die Bürogemeinschaft. Die von beiden Anwälten je zur Hälfte zu tragenden Kosten, die im ersten Jahr dieser Kooperation angefallen sind, betragen 125.000 € (im Wesentlichen Personalkosten) zzgl. 5.280 € USt.

► **Lösung:**

Die von Dr. Katz und Dr. Maus gebildete Bürogemeinschaft ist keine umsatzsteuerlich unbeachtliche Innengesellschaft. Sie tätigt zwar keine Umsätze mit Außenstehenden, tritt aber bei der Anmietung der Kanzleiräumlichkeiten und bei der Anstellung des Personals in sonstiger Weise nach außen hervor. Die Bürogemeinschaft ist somit umsatzsteuerliche Unternehmerin (§ 2 Abs. 1 UStG), so dass sie aus den Leistungsbezügen den Vorsteuerabzug in Höhe von 5.280 € vornehmen kann (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).



3.4.2.2 Arbeitsgemeinschaften

Haupterscheinungsform eines Unternehmerzusammenschlusses mit Unternehmereigenschaft ist die nach außen auftretende **Arbeitsgemeinschaft (ARGE)**, wie sie im **Baugewerbe** sehr häufig vorkommt. Solche Zusammenschlüsse kommen im Regelfall zustande, wenn ein Auftrag (zB. Bau einer Brücke, eines Hochhauses, eines U-Bahn-Streckenabschnitts) die Leistungsfähigkeit des einzelnen in Betracht kommenden Unternehmens übersteigt. Dabei schließen sich die Unternehmer idR. in der **Form** einer **GbR** zusammen und treten als Gemeinschaft in Rechtsbeziehungen zum Auftraggeber. Die Unternehmereigenschaft der Arbeitsgemeinschaft ist auch gegeben, wenn einer der beteiligten Unternehmer die Geschäfte der Gemeinschaft in deren Namen und für deren Rechnung führt.

Schließen sich Unternehmer nur zur **Erreichung eines einzigen Zwecks** (Erledigung eines Bauauftrags) zusammen, so ist die ARGE kraft Gesetzes aufgelöst, wenn der Auftrag erfüllt und damit der Zweck der Gesellschaft erreicht ist. Umsatzsteuerlich besteht die GbR als Unternehmer so lange fort, bis alle gemeinsamen Rechtsbeziehungen, zu denen auch das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Finanzamt gehört, unter den Gesellschaftern erledigt sind (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 6 UStAE).

Zwischen der ARGE und den beteiligten Unternehmern liegt kein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch, sondern nur **nichtsteuerbare Gesellschafterbeiträge** vor, wenn die Leistungspflicht im Vertrag über die Errichtung der ARGE festgelegt ist, jeder Gesellschafter die gegenüber der ARGE übernommenen Leistungen auch tatsächlich erbringt und diese nicht durch bestimmte, leistungsbezogene Sonderentgelte, sondern durch eine **Beteiligung am Gewinn und Verlust** abgegolten werden (Abschn. 1.6 Abs. 3, Abs. 8 Satz 2 UStAE; vgl. hierzu bereits im Lehrbrief USt 03, unter dem Titel „Leistungsaustausch bei Gesellschafterverhältnissen“).

Eine nachträgliche Feststellung der Gewinnbeteiligung nach dem **Umfang der tatsächlich erbrachten Leistung** macht die ausgeschütteten Beträge dagegen zu Entgelten, so dass ein Leistungsaustausch gegeben ist (Abschn. 1.6 Abs. 8 Satz 3 UStAE).

► **Fallbeispiel:**

Im Januar erhielten die Fa. GR Bau-KG, Eching, und die Baufirma Jörger aus Freising vom Zweckverband „Hollедauer Hopfen“ als ARGE gemeinsam den Auftrag, eine Lagerhalle für Hopfen zu errichten. Das Bauwerk wurde, wie vertraglich vereinbart, am 30.6. fertig gestellt und übergeben.



Der Zweckverband hatte das gesamte verwendete Baumaterial unmittelbar bei einem Baustoffgroßhandel eingekauft und für den Hallenbau beigestellt. Beim Einkauf des Baumaterials war der Zweckverband von der ARGE beraten worden.

Die ARGE „Lagerhalle Mainburg“ erteilte dem Zweckverband eine Rechnung über 400.000 € zzgl. 76.000 € USt. Die bei der ARGE für Leistungen Dritter angefallenen Aufwendungen betrugen 80.000 €. Der Wert des Baumaterials (800.000 €) ist hierin nicht enthalten.

Zwischen der KG und Jörger war im ARGE-Vertrag vereinbart, dass Personal und Baugeräte als Gesellschafterbeiträge je zur Hälfte ohne Berechnung zur Verfügung zu stellen seien und der Gewinn aus dem Auftrag hälftig verteilt werden sollte.

Dafür, dass Jörger zwei Großkräne zusätzlich abstellte, sollte er 10 % des Gewinns vorab erhalten. Der Umfang der Geräteüberlassung wurde jedoch abweichend von der ursprünglichen Vereinbarung nach der Geräteliste der Wirtschaftsgruppe Bauindustrie betragsmäßig festgehalten, also nach dem tatsächlichen Maschinen- und Geräteeinsatz. Nach diesen Aufzeichnungen entfielen jeweils brutto auf den Einsatz der Großkräne 71.400 € und auf den Einsatz der anderen Geräte des Jörger 95.200 €; der Geräteeinsatz der KG ergab 130.900 €.

Die KG und Jörger rechneten nach diesen Werten ab und verteilten den verbleibenden Restgewinn zu gleichen Teilen. Mit diesem hälftig verteilten Restgewinn sollten der Personaleinsatz und die Aufwendungen für Kleinmaterial abgegolten werden.

► **Lösung:**

Die von der KG mit der Fa. Jörger gebildete ARGE ist mit der Ausführung des Auftrags der Zweckgemeinschaft als Personengesellschaft nach außen aufzutreten; sie ist Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG.

An dem Leistungsaustausch, einer steuerbaren und steuerpflichtigen Werkleistung (§ 3 Abs. 9 UStG), nehmen die vom Auftraggeber beschafften und beigestellten Baumaterialien nicht teil (echte Materialbereitstellung, Abschn. 3.8 Abs. 2 UStAE zur Werklieferung, hier entsprechend). Die USt iHv. 76.000 € entsteht mit Ablauf des VAZ Juni (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG, Abschn. 13.2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UStAE).

Die KG und die Firma Jörger konnten die Geräteüberlassung wie alle anderen Leistungen an die ARGE im Rahmen eines Leistungsaustauschs oder als nichtsteuerbare Gesellschafterbeiträge erbringen. Stehen den Leistungen der ARGE-Partner gewinnunabhängige und damit leistungsbezogene Entgelte gegenüber, so erbringen KG und Jörger mit der Geräteüberlassung steuerbare sonstige Leistungen; Voraussetzung für die Annahme eines leistungsabhängigen Entgelts ist, dass auf der Grundlage der tatsächlichen Geräteverwendung abgerechnet wird (Abschn. 1.6 Abs. 8 Satz 1, 3 UStAE). Dies ist hier der Fall. Auf die anders lautende Vereinbarung kommt es nicht an, weil nicht die Vereinbarung als solche, sondern die tatsächliche, gewinnunabhängige Vergütung von Leistungen der ARGE-Partner für die umsatzsteuerliche Beurteilung maßgebend ist.

Entgelt für Geräteüberlassung durch die KG ^{100/119} von 130.900 €	110.000 €
Umsatzsteuer 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG)	<u>20.900 €</u>
	130.900 €
Geräteüberlassung durch Fa. Jörger (^{100/119} von 95.200 €)	80.000 €
Überlassung der Baukräne (^{100/119} von 71.400 €)	<u>60.000 €</u>
	140.000 €
Umsatzsteuer 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) von 140.000 €	26.600 €

Die übrigen Leistungen der ARGE-Partner (Gestellung von Arbeitskräften ua.) werden nicht durch eine leistungsbezogene Gegenleistung abgegolten. Die Gewinnausschüttung erfolgt nach den Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag, also nicht leistungsabhängig.

Der Zufluss des Gewinns beim Gesellschafter beruht auf einem Gemeinschaftsverhältnis der Gesellschafter untereinander, nicht dagegen auf einem Austauschverhältnis, dh. einer konkreten Leistungsbeziehung der Gesellschafter zur Gesellschaft.

Es liegen mit den Leistungen der ARGE-Partner echte Gesellschafterbeiträge vor, die nicht im Rahmen eines Leistungsaustauschs erbracht werden (Abschn. 1.6 Abs. 8 Satz 2 UStAE).

4. Selbständigkeit

Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG kann nur sein, wer die **gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt**. Voraussetzung ist ein Handeln auf eigenes Risiko und nach eigener Willensentscheidung. Das UStG selbst gibt keine gesetzliche Definition des Begriffs der Selbständigkeit, es enthält lediglich insofern eine Erläuterung des Begriffs, als es in **§ 2 Abs. 2 UStG** aussagt, wann eine Tätigkeit **nicht selbständig** ausgeübt wird. Dabei unterscheidet das UStG zwischen der Selbständigkeit natürlicher Personen und der Selbständigkeit juristischer Personen.

4.1 Selbständigkeit oder Unselbständigkeit natürlicher Personen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Selbstständigkeit natürlicher Personen – v10271

Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG sind natürliche Personen insoweit unselbständig, als sie einem Unternehmen derart eingegliedert sind, dass sie den Weisungen des Unternehmers zu folgen verpflichtet sind. Die Frage nach Selbständigkeit oder Unselbständigkeit beantwortet sich demnach grundsätzlich nach dem Innenverhältnis zum Auftraggeber. Korrespondierend dazu bestimmt § 1 Abs. 3 LStDV, dass nicht Arbeitnehmer sein kann, wer entgeltliche Lieferungen und sonstige Leistungen innerhalb der von ihm selbständig ausgeübten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit ausführt. Die Selbständigkeit oder Unselbständigkeit ist für die **Umsatzsteuer-, Einkommenssteuer und Gewerbesteuer** grds. nach denselben Grundsätzen zu beurteilen (Abschn. 2.2 Abs. 2 Satz 1 UStAE).

Die Selbständigkeit ist nicht nach zivilrechtlichen, sondern nach **wirtschaftlichen Gesichtspunkten** zu beurteilen. Von den Merkmalen, die das Gesamtbild der Tätigkeit einer Person bestimmen, kommt dem Umstand wesentliche Bedeutung zu, wer das Risiko der wirtschaftlichen Betätigung trägt. Muss der Betreffende mit der Möglichkeit eines Verlusts aus seiner Betätigung rechnen und ist er in der Gestaltung seiner Betriebsausgaben frei, so ist er in der Regel Unternehmer. Gegen Selbständigkeit spricht in der Regel die Zahlung einer erfolgsunabhängigen Vergütung.

Ein Eingliederungsverhältnis liegt vor, wenn der Beschäftigte dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft schuldet, er also in der Betätigung seines geschäftlichen Willens unter der Leitung des Arbeitgebers steht. Für Unselbständigkeit spricht es insbesondere, wenn Arbeitszeit, -ort und -art, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall usw. durch einen **Arbeitsvertrag** bindend festgelegt sind, wenn das Arbeitsverhältnis für längere Zeit und nicht nur gelegentlich ausgeübt wird und wenn der Umfang an Zeit und Bewegungsfreiheit allein durch den Arbeitgeber entschieden wird.

Eine wirtschaftliche Abhängigkeit allein führt nicht zur Nichtselbständigkeit im steuerrechtlichen Sinne. Selbst eine **totale wirtschaftliche Abhängigkeit** von einem einzigen Auftraggeber, der als Großkunde die Bedingungen der wirtschaftlichen Beziehungen bestimmen kann, kann im Einzelfall die Unternehmereigenschaft nicht ausschließen.

Ob Selbständigkeit oder Unselbständigkeit anzunehmen ist, bestimmt sich nach dem **Gesamtbild der Verhältnisse**. Die für und gegen die Unternehmereigenschaft sprechenden Merkmale, die im Einzelfall unterschiedlich gewichtet werden können, sind gegeneinander abzuwägen (Abschn. 2.2 Abs. 1 Satz 5, 6 UStAE).



Der BFH führt folgende Merkmale an, die für Unselbständigkeit bzw. Selbständigkeit einer Tätigkeit sprechen können und im Rahmen der Gesamtschau zu berücksichtigen sind:

- persönliche Abhängigkeit,
- Weisungsgebundenheit bezüglich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit,
- feste Arbeitszeiten,
- Ausübung der Tätigkeit gleichbleibend an einem bestimmten Ort,
- feste Bezüge,
- Urlaubsanspruch,
- Anspruch auf sonstige Sozialleistungen,
- Fortzahlung der Bezüge im Krankheitsfall,
- Notwendigkeit der engen ständigen Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern,
- Eingliederung in den Betrieb,
- Schulden der Arbeitskraft und nicht eines Arbeitserfolgs,
- Ausführung von einfachen Tätigkeiten, bei denen eine Weisungsgebundenheit die Regel ist,
- Selbständigkeit in Organisation und Durchführung der Tätigkeit,
- Unternehmerrisiko,
- Unternehmerinitiative,
- Bindung an den Betrieb nur für bestimmte Tage,
- geschäftliche Beziehungen zu mehreren Vertragspartnern.

Bei der Frage, ob **Gesellschafter-Geschäftsführer** ihre Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen gegenüber der Gesellschaft selbständig ausüben, ist nach Abschn. 2.2 Abs. 2 UStAE danach zu unterscheiden, ob sie nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG weisungsgebunden sind oder nicht. Dies gilt grds. gleichermaßen für eine Tätigkeit für eine Personengesellschaft als auch eine Kapitalgesellschaft. Die Beurteilung hat dabei unabhängig vom Ertragsteuerrecht zu erfolgen, wie auch aus den Beispielen in Abschn. 2.2 Abs. 2 UStAE deutlich wird. Dem Ertragsteuerrecht kommt nur indizielle Bedeutung und keine Bindungswirkung zu. Damit kann ein Gesellschafter-Geschäftsführer zwar ertragsteuerlich Mitunternehmer und damit gewerblich tätig sein, umsatzsteuerlich jedoch nicht selbstständig und damit nicht unternehmerisch.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 war ein GmbH-Geschäftsführer explizit laut einer Vereinbarung im Arbeitsvertrag der GmbH gegenüber weisungsgebunden und damit nicht selbstständig tätig. Daneben waren zwei OHG-Geschäftsführer auf ihre Unternehmereigenschaft hin zu prüfen und deren Selbstständigkeit lag insoweit vor. Wie auch hier sind regelmäßig insoweit relativ eindeutig formulierte Sachverhaltsgestaltungen zu lösen.

Aufsichtsratsmitglieder können ihre Tätigkeit entweder selbstständig oder nicht selbstständig ausüben. Die Differenzierung erfolgt vorrangig dahingehend, ob das Aufsichtsratsmitglied eine fixe oder variable Vergütung erhält (Abschn. 2.2 Abs. 3a UStAE). Eine Selbstständigkeit kommt demnach lediglich in Betracht, wenn die Vergütung variabel ist, zB. durch Zahlung von Sitzungsgeldern bzw. der variable Teil der Vergütung mindestens 10 % einer gemischten Vergütung beträgt.

4.2 Unselbständigkeit juristischer Personen bzw. von Personengesellschaften (Organschaft)



PRÜFUNGSTIPP

Die umsatzsteuerliche Organschaft wird immer wieder in der Steuerberaterprüfung zum Gegenstand der Teilaufgabe Umsatzsteuer gemacht, so zuletzt in den Prüfungen der Jahre 2024 und 2016.

Juristische Personen des Privatrechts sind selbständig tätig, soweit sie nicht als **Organgesellschaften** in das Unternehmen eines Organträgers eingegliedert sind. **Organträger** kann jeder Unternehmer und damit eine natürliche Person, eine Personenvereinigung oder eine Kapitalgesellschaft sein (Abschn. 2.8 Abs. 2 Satz 1 UStAE). Als Organgesellschaften kommen zwar grundsätzlich gesetzlich durch § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nur juristische Personen des Zivil- und Handelsrechts in Betracht (Abschn. 2.8 Abs. 2 Satz 4 UStAE). Ausnahmsweise können aber nach Rechtsprechung des BFH sowie der Auffassung der Finanzverwaltung in Abschn. 2.8 Abs. 5a UStAE entgegen des Wortlauts des deutschen UStG aufgrund des Unionsrechts auch **Personengesellschaften** Organgesellschaften sein (vgl. im Einzelnen unten). Liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, sind die Organgesellschaften wie **unselbständige Unternehmensteile** des Organträgers anzusehen. Unternehmer ist einzig und allein der Organträger.

4.2.1 Die Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft



PRÜFUNGSTIPP

Die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft waren zuletzt in der Steuerberaterprüfung 2024 sowie 2016 zu prüfen. In der Steuerberaterprüfung 2024 zogen sich die Folgen der Organschaft durch die gesamte Prüfung hindurch, da sich die Eingliederungskriterien unterjährig änderten. In der Steuerberaterprüfung 2016 war die Organschaft nach Gründung und Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH zu prüfen. Das Ergebnis stellt dabei eine wichtige Weichenstellung für die weitere Klausurbearbeitung dar. Wer hier falsch entscheidet, gelangt auf das falsche Gleis. Und wer sich einmal auf dem falschen Gleis befindet, erzielt in aller Regel keine Wertungspunkte mehr. Wenn Sie in einer Klausur an eine solche Weichenstellung gelangen, müssen Sie besondere Sorgfalt walten lassen und sich die für eine genaue Prüfung notwendige Zeit nehmen.

Eine (umsatzsteuerlich nichtselbständige) **Organgesellschaft** liegt nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vor, wenn

- eine juristische Person als Organgesellschaft
- in das Unternehmen eines anderen Unternehmers
- nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliedert ist.



HINWEIS

Die Voraussetzungen für die umsatzsteuerliche Organschaft sind nicht identisch mit den Voraussetzungen der körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen Organschaft (Abschn. 2.8 Abs. 3 UStAE).



4.2.1.1 Personengesellschaft als Organgesellschaft?

Lange Zeit war strittig, ob eine umsatzsteuerliche Organschaft auch mit einer Tochter-Personengesellschaft möglich ist. Nach nationalem Recht wäre dies zwar gesetzlich ausgeschlossen, da § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nur **juristische Personen** (insbes. AG, GmbH etc.) als potenzielle Organgesellschaften anerkennt. Nach Art. 11 MwStSystRL können demgegenüber **Personen**, die finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eng miteinander verbunden sind, eine Organschaft begründen. Eine Eingrenzung auf juristische Personen findet hier nicht statt.

Folglich lässt der BFH im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH eine Organschaft entgegen dem Wortlaut des Gesetzes auch mit Tochter-Personengesellschaften zu:

- Der **V. Senat** des BFH kommt in seinem Urteil vom 2.12.2015, V R 25/13, zu diesem Ergebnis im Wege der teleologischen Extension des Begriffs „juristische Person“. Voraussetzung dafür ist, dass Gesellschafter der Personengesellschaft nur der Organträger und andere vom Organträger finanziell beherrschte Gesellschaften sind. Sofern die Personengesellschaft mit sämtlichen Gesellschaftsanteilen finanziell in einer bis zum Organträger reichenden Kette eingegliedert ist, kann sie in die Organschaft eingebunden sein.
- Der **XI. Senat** des BFH lässt mit Urteil vom 19.1.2016, XI R 38/12 eine GmbH & Co. KG (= Personengesellschaft) als potenzielle Organgesellschaft zu. Er begründet dies mit der richtlinienkonformen Auslegung des Begriffs „juristische Person“ iSv. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Die Einschränkungen des V. Senat, verlangt der XI. Senat bei einer GmbH & Co. KG nicht.

Die **Finanzverwaltung** hat sich der obigen Auffassung des V. Senats angeschlossen (Abschn. 2.8 Abs. 2 Satz 5 und Abs. 5a Satz 1 UStAE).



HINWEIS

Der EuGH hat in seinem aktuellen Urteil dieser nationalen einschränkenden Auffassung eine Absage erteilt. Der V. Senat des BFH hat daraufhin seine obige Auffassung revidiert und an diejenige des XI. Senats angepasst (vgl. BFH-Urteil vom 16.3.2023, V R 14/21). Dennoch empfehlen wir Ihnen für die Steuerberaterprüfung weiterhin von Abschn. 2.8 Abs. 2 Satz 5 und Abs. 5a Satz 1 UStG auszugehen und die Eingliederung einer Personengesellschaft entgegen dem Gesetzeswortlaut anzuerkennen, sofern alle Gesellschafter der Personengesellschaft in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Personengesellschaft als Organschaft – v14443

4.2.1.2 Keine Organschaft mit Nichtunternehmern

Nach der nationalen Vorschrift des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG muss der Organträger umsatzsteuerlicher Unternehmer sein, was auch den Vorgaben der MwStSystRL entspricht. Auch die Finanzverwaltung vertritt in ihrem Anwendungserlass diese Auffassung (Abschn. 2.8 Abs. 2 Satz 9 UStAE). Eine Organschaft kann damit zumindest national in Deutschland nicht mit einem Nichtunternehmer als Organträger gebildet werden.

4.2.1.3 Die Eingliederungsvoraussetzungen

Die Organgesellschaft muss finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein. Alle drei Voraussetzungen müssen gleichzeitig vorliegen, dürfen jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Auch hier ist wiederum eine Abwägung aller Umstände des Einzelfalls im Rahmen einer Gesamtschau maßgeblich (Abschn. 2.8 Abs. 1 Satz 2, 3 UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Eingliederungsvoraussetzungen – v10217

4.2.1.3.1 Finanzielle Eingliederung

Unter der **finanziellen Eingliederung** ist der Besitz der entscheidenden Anteilsmehrheit an der Organgesellschaft zu verstehen, die es ermöglicht, Beschlüsse in der Organgesellschaft durchzusetzen. Entsprechen die Beteiligungsverhältnisse den Stimmrechtsverhältnissen, ist die finanzielle Eingliederung gegeben, wenn die Beteiligung mehr als 50 % beträgt (Abschn. 2.8 Abs. 5 Satz 2 UStAE).



HINWEIS

Mit Urteil vom 18.1.2023, XI R 29/22 (XI R 16/18), hat der BFH entschieden, dass eine finanzielle Eingliederung nunmehr aber auch dann vorliegen kann, wenn die erforderliche Willensdurchsetzung dadurch gesichert ist, dass der Gesellschafter zwar nur über 50 % der Stimmrechte verfügt, er im Übrigen eine Mehrheitsbeteiligung am Kapital der Organgesellschaft hält und er den einzigen Geschäftsführer der Organgesellschaft stellt.



PRÜFUNGSTIPP

Da die Verwaltung das Urteil vom 18.1.2023 bisher noch nicht in dem Umsatzsteueranwendungserlass umgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, in der Steuerberaterprüfung sich an die bisherige Verwaltungsmeinung im Abschn. 2.8 Abs. 5 UStAE zu halten.

Bei der in der Praxis häufig anzutreffenden Fallkonstellation von Schwestergesellschaften liegt keine umsatzsteuerliche Organschaft vor (Abschn. 2.8 Abs. 5b Satz 4, 5 UStAE).

4.2.1.4 Wirtschaftliche Eingliederung

Wirtschaftliche Eingliederung bedeutet, dass die Organgesellschaft nach dem Willen des Unternehmers im Rahmen des Gesamtunternehmens, und zwar in engem wirtschaftlichem Zusammenhang mit diesem, wirtschaftlich tätig ist (Abschn. 2.8 Abs. 6 UStAE). Sie kann sich ua. dadurch ergeben, dass Leistungsbeziehungen zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft bestehen, zB. da der Organträger eine wesentliche Betriebsgrundlage an die Organgesellschaft entgeltlich überlässt.

4.2.1.5 Organisatorische Eingliederung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

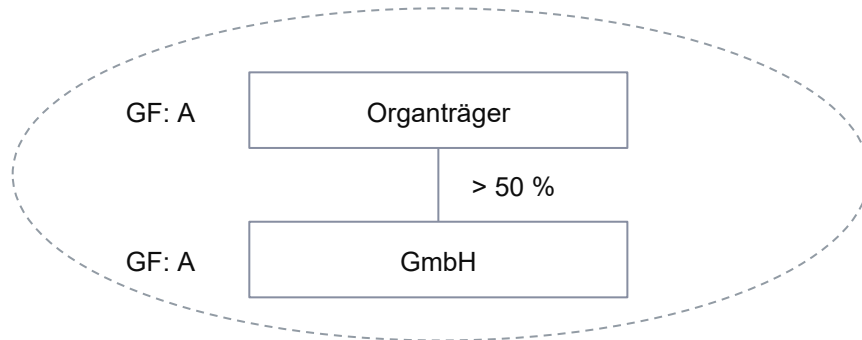
Organisatorische Eingliederung – v10216

Die mit der finanziellen Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft muss in der **laufenden Geschäftsführung** auch tatsächlich wahrgenommen werden. Eine vom Willen des Organträgers abweichende Willensbildung bei der Organtochter darf nicht nur nicht stattfinden, sondern es braucht einer aktiven Willensdurchsetzung (Abschn. 2.8 Abs. 7 Satz 2, 3 UStAE). Der Organträger muss die Organgesellschaft folglich beherrschen. Ein bloßes Vetorecht des Organträgers genügt folglich nicht.

Der UStAE versucht darüber hinaus, die Anforderungen an die organisatorische Eingliederung über ein **Stufenverhältnis** abzubilden.

Stufe 1: Personalunion der Geschäftsführungsorgane

Bei Personenidentität in den Leitungsgremien kann grundsätzlich von der organisatorischen Eingliederung ausgegangen werden.

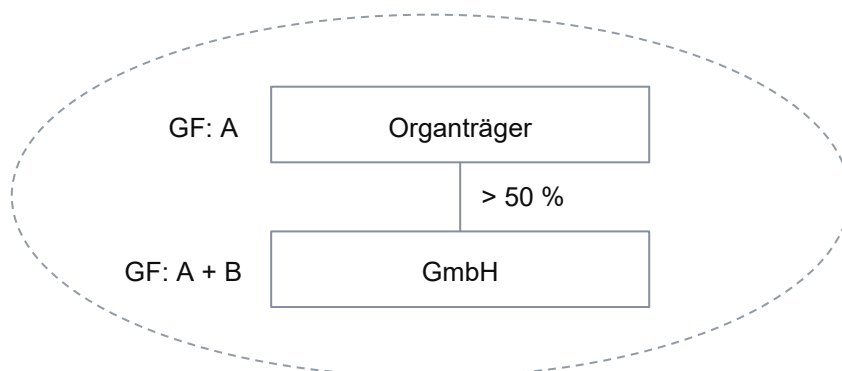


Ausreichend ist auch, wenn nur einzelne Geschäftsführer des Organträgers als Geschäftsführer in der Organgesellschaft wirken.

Neben dem Regelfall der personellen Verflechtung kann sich die organisatorische Eingliederung auch daraus ergeben, dass **Mitarbeiter** des Organträgers als Geschäftsführer in der Organgesellschaft tätig sind. Letzteres beruht auf der Annahme, dass der Mitarbeiter den Weisungen seines Dienstherrn aufgrund Anstellungsverhältnis und einer sich hieraus ergebenden persönlichen Abhängigkeit Folge zu leisten hat und er bei weisungswidrigem Verhalten als Geschäftsführer der Organgesellschaft abberufen werden kann. Der UStAE weist aber auch darauf hin, dass eine reine Prokura-Stellung (ohne Anstellungsverhältnis) nicht ausreichend ist. Der Mitarbeiter muss dabei kein sog. leitender Mitarbeiter sein; auch einfache Mitarbeiter des Organträgers genügen nun (Abschn. 2.8 Abs. 9 UStAE).

Stufe 2: Teilweise Personalunion

Liegt keine Personenidentität in den Leitungsgremien vor, da zB. mindestens ein weiterer (Fremd-) Geschäftsführer in der Organgesellschaft tätig ist, müssen weitere Merkmale hinzukommen, um eine organisatorische Eingliederung zu bejahen.



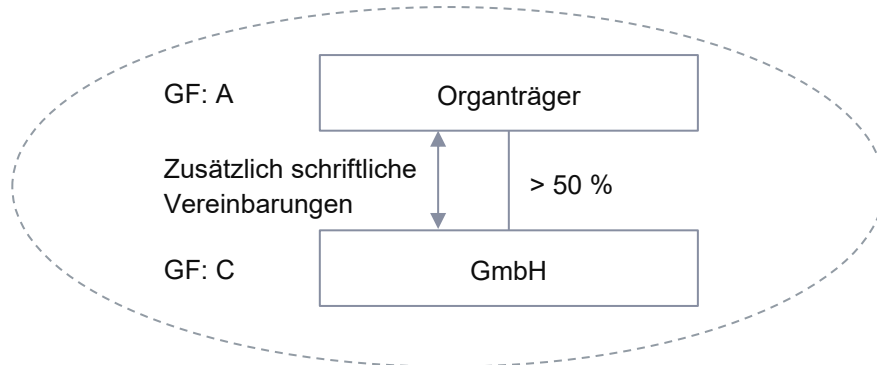
Entscheidend ist insbesondere die Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnis in der Tochtergesellschaft. Von einer organisatorischen Eingliederung kann nach Abschn. 2.8 Abs. 8 Satz 6 UStAE ausgegangen werden, wenn eine **Gesamtgeschäftsführungsbefugnis** vereinbart ist und die personenidentischen Geschäftsführer die Stimmenmehrheit besitzen. Ist dies nicht der Fall, so sind zusätzliche institutionell abgesicherte Maßnahmen erforderlich.

Diese können zB. sein:

- ein umfassendes Weisungsrecht des Organträgers gegenüber der Geschäftsführung der Organgesellschaft mit Berechtigung zur Bestellung und Abberufung aller Geschäftsführer der Organgesellschaft (Abschn. 2.8 Abs. 8 Satz 8 UStAE), oder
- ein schriftlich vereinbartes Letztentscheidungsrecht des personenidentischen Geschäftsführers bei Einzelgeschäftsführungsbefugnis (Abschn. 2.8 Abs. 8, Satz 9 UStAE).

Stufe 3: Keine Personenidentität der Geschäftsführung

In Ausnahmefällen kann eine organisatorische Eingliederung auch **ohne** personelle Verflechtung in den Leitungsgremien vorliegen (Abschn. 2.8 Abs. 10 UStAE).



Voraussetzung ist dann aber grundsätzlich, dass **institutionell abgesicherte unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten** in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der Organgesellschaft gegeben sind. Von solchen Eingriffsmöglichkeiten ist auszugehen, wenn der Organträger mit der Organgesellschaft einen **Beherrschungsvertrag** nach § 291 AktG abgeschlossen hat oder die Organgesellschaft nach §§ 319, 320 AktG in die Gesellschaft des Organträgers eingegliedert ist. Darüber hinaus lässt der UStAE auch schriftlich fixierte Vereinbarungen wie zB. eine Geschäftsführerordnung, Konzernrichtlinien oder einen Anstellungsvertrag ausreichen (Abschn. 2.8 Abs. 10 Satz 3 ff. UStAE).

Die organisatorische Eingliederung kann auch über eine **Beteiligungskette** vermittelt werden (Abschn. 2.8 Abs. 10a UStAE). Auf die dort genannten Beispiele 1–4 wird verwiesen.

► Fallbeispiel:

Karoline Joerger (Komplementärin, 60 %-Anteil), Dieter Schadt und Fritz Spieth (Kommanditisten, je 20 %-Anteil) sind Gesellschafter der Fa. Joerger Baustoff- und Ziegelei KG. Die KG hält 70 % der Anteile an der Esslinger Baustoff-Handelsgesellschaft mbH. Die KG setzt ihre Produkte zu 70 % bei verschiedenen Bauunternehmen und Baustoffhändlern ab, 30 % verkauft sie an die Esslinger Baustoff-Handelsgesellschaft mbH. Bei der GmbH machen die von der KG bezogenen Baustoffe und Ziegel zwei Drittel des Warenbezugs aus. Die restlichen Baustoffe bezieht die GmbH von anderen Herstellern und Großhändlern. Geschäftsführerin der GmbH ist Karoline Joerger.

► Lösung:

Die GmbH ist Organgesellschaft der KG, da sie finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen der KG eingegliedert ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG):

Finanzielle Eingliederung ist gegeben, da die KG die Mehrheit des Stammkapitals der GmbH hält (Abschn. 2.8 Abs. 5 UStAE).

Wirtschaftliche Eingliederung: Da die GmbH ihre Baustoffe zu zwei Drittel von der KG bezieht, ist die wirtschaftliche Verflechtung gegeben (Abschn. 2.8 Abs. 6 UStAE).

Organisatorische Eingliederung: Die Geschäftsführung durch Joerger bei der GmbH stellt sicher, dass die Organgesellschaft ihre Geschäftstätigkeit nach dem Willen des Organträgers ausübt (Abschn. 2.8 Abs. 7, 8 UStAE: Stufe 1 – Personalunion).



4.2.2 Beginn und Ende der Organschaft

Die Organschaft **beginnt** sofort, sobald die Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG erfüllt sind. Sie endet sofort zu dem Zeitpunkt, zu dem **eine** der Eingliederungsvoraussetzungen wegfällt, zB. durch Veräußerung der Geschäftsanteile durch den Organträger, die zum Wegfall der finanziellen Eingliederung führt. Wird die organisatorische Eingliederung durch Abschluss eines Beherrschungsvertrags bei einer GmbH begründet, treten die Wirkungen ein, sobald dieser ins Handelsregister eingetragen wird (Abschn. 2.8 Abs. 10 Satz 7 UStAE).

Ein Wahlrecht zur Organschaft besteht damit ausdrücklich nicht (Abschn. 2.8 Abs. 4 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

Achten Sie in der Klausur daher insbesondere auf Anteilszerwerbe oder -veräußerungen. Diese können Auswirkung auf den Umfang des Unternehmens und das Bestehen einer Organschaft haben. In der Steuerberaterprüfung 2024 führte daneben ein Wechsel in der Geschäftsführung zur Begründung einer Organschaft.

Nach Abschn. 2.8. Abs. 12 UStAE endet die Organschaft mit Insolvenzeröffnung beim Organträger oder der Organgesellschaft (auch in Eigenverwaltungsfällen) sowie bei Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, wenn dieser nichtgeschäftliche Verfügungen des Schuldners, so verbinden kann.

4.2.3 Die Wirkungen der Organschaft

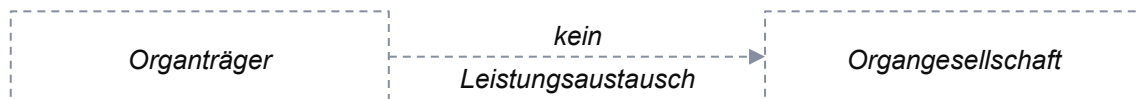


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wirkungen der Organschaft – v10285

Die im Organkreis zusammengefassten Unternehmen bilden ein **einheitliches Unternehmen**, dessen Unternehmer der Organträger ist. Die Organgesellschaft ist umsatzsteuerlich ein unselbstständiger Unternehmensteil des Organträgers, wie sich aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG ergibt.

Umsätze zwischen dem Organträger und seiner Organgesellschaft und umgekehrt sowie zwischen den Organgesellschaften sind **innerbetriebliche Vorgänge**, die nicht steuerbar sind (Abschn. 2.7 Abs. 1 Satz 3 UStAE).



HINWEIS

Die Nichtsteuerbarkeit von Innenumsätzen innerhalb der Organschaft stand hinsichtlich ihrer Unionsrechtskonformität nach einer Vorlage des BFH vom 26.1.2023 (Az. V R 20/22) auf dem Prüfstand beim EuGH. Sowohl der EuGH (Urteil vom 11.7.2024, CC-184/23) als auch der BFH in seinem Nachfolgeurteil vom 29.08.2024 (V R 14/24) bestätigten nun, dass die Regelung unionsrechtskonform und die Innenumsätze nicht steuerbar sind.

Werden für solche Innenumsätze – zB. weil die Organschaft nicht erkannt wird – Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erstellt, so kommt, weil keine Leistung eines anderen Unternehmers vorliegt, ein Vorsteuerabzug aus einer solchen Abrechnung nicht in Frage. Die Steuer wird vom Leistenden aber **nicht nach § 14c Abs. 2 UStG geschuldet**, weil dieser „unternehmensinterne Buchungsbeleg“ keine Rechnung iSd. § 14 UStG (Abschn. 14.1 Abs. 4 UStAE) darstellt.

Die **Umsätze der Organgesellschaft** an fremde Dritte sind **Umsätze des Organträgers**, die zu seinem Gesamtumsatz rechnen. Umsatzsteuerbeträge, die für Leistungen Dritter an die Organgesellschaft berechnet werden, sind beim Organträger abziehbare Vorsteuer. Organträger und Organgesellschaft werden umsatzsteuerlich als ein Unternehmen bei dem Finanzamt geführt, das nach § 21 AO für den Organträger zuständig ist.

Auf Antrag wird sowohl dem Organträger als auch der Organgesellschaft eine **eigene USt-IdNr.** erteilt (§ 27a Abs. 1 Satz 4 UStG).

4.2.4 Keine grenzüberschreitende Wirkung der Organschaft

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 UStG bleiben die Wirkungen der umsatzsteuerlichen Organschaft auf die Leistungen zwischen den im Inland ansässigen bzw. belegenen Unternehmensteilen eines Organkreises beschränkt, auch wenn an sich ein grenzüberschreitendes Organverhältnis vorläge (Abschn. 2.9 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Die im **Inland gelegenen Unternehmensteile** des Organkreises sind als ein **Unternehmen** zu behandeln. Hat der Organträger seine Geschäftsleitung im Ausland, gilt der wirtschaftlich bedeutendste Unternehmensteil im Inland als der Unternehmer.

Die **Wirkung einer Organschaft** entfällt für einen Leistungsaustausch, der zwischen den im Inland belegenen Unternehmensteilen und den im Ausland gelegenen Unternehmensteilen sowie zwischen im Ausland gelegenen Unternehmensteilen bewirkt wird (Abschn. 2.9 Abs. 1 UStAE).

Nicht erfasst sind Umsätze und Leistungsbezüge der Organgesellschaften, die mit Dritten grenzüberschreitend bewirkt werden. Diese Vorgänge sind nach wie vor dem Organträger zuzurechnen.

► **Fallbeispiel:**

Die BMW AG München unterhält eine BMW-Sport Ges.mbH mit Sitz in Linz/Österreich, die die rennsportlichen Aktivitäten von BMW in Österreich, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei koordiniert und betreut. Die BMW AG hält 100 % der Anteile an der BMW-Sport Ges.mbH. Linz. Im vergangenen Jahr lieferte die BMW AG, München, Rennmotoren und sonstiges Rennsport-Zubehör für 2,4 Mio. € an die Tochtergesellschaft in Linz.

► **Lösung:**

Die Lieferungen der BMW AG an die Tochtergesellschaft sind an sich Lieferungen des Organträgers an die Organgesellschaft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG), also nichtsteuerbare Inenumsätze. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 UStG sind aber die Wirkungen der Organschaft auf das Inland beschränkt, so dass die Lieferungen der BMW AG an ihre Organgesellschaft in Österreich keine nichtsteuerbaren Inenumsätze sind; sie sind vielmehr steuerbare und bei Vorliegen der Voraussetzungen steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 3 Abs. 1 und Abs. 6 Satz 1 UStG, § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG und § 6a Abs. 1 UStG).

5. Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gewerbliche oder berufliche Tätigkeiten – v14444



5.1 Allgemeines

Gewerblich oder beruflich ist nach § 2 Abs. 1 Satz 3 UStG **jede selbständige und nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen**, ohne Rücksicht darauf, ob die Tätigkeit von der Absicht bestimmt ist, Gewinn zu erzielen. Der Begriff der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit hat in der Umsatzsteuer einen völlig eigenständigen Inhalt, er lehnt sich weder an die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des HGB oder der Gewerbeordnung an, noch entspricht er dem Begriff des Gewerbebetriebs iSd. EStG oder GewStG oder der selbständigen Arbeit im EStG. Auch mit dem Sprachgebrauch deckt sich der umsatzsteuerliche Begriff nicht. Als gewerbliche oder berufliche Tätigkeit kommt umsatzsteuerlich jede Art von (wirtschaftlicher) Tätigkeit (Leistung) in Betracht, die selbständig ausgeübt wird.



HINWEIS

Im Unterschied zum einkommensteuerlichen Gewerbebegriff (H 15.4 EStH) setzt die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht voraus. § 2 Abs. 1 Satz 3 UStG stellt klar, dass ein steuerbares unternehmerisches Leistungsverhalten bereits vorliegt, wenn „eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird“, sich also am allgemeinen Wirtschaftsverkehr nicht beteiligt.

▶ Fallbeispiel:

Hans Glück erbt von seiner Tante Frieda ein Zweifamilienhaus, in dem Glück bereits eine Wohnung selbst mit seiner Familie bewohnt. Die zweite Wohnung hat eine weitere Tante des Erben inne. Das Erbe ist mit der Auflage versehen, diese zweite Wohnung der Tante auf Lebenszeit zu einer ortsüblichen Miete zu überlassen.

▶ Lösung:

Hans Glück wird durch die Vermietung ab Erbanfall Unternehmer iSd. § 2 Abs. 1 UStG. Der Unternehmereigenschaft steht nicht entgegen, dass die Vermieterleistungen, wie hier, nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfrei sind und dass er keine Möglichkeit hat, die Wohnung anderen Mietinteressenten zur Miete anzubieten (also keine Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr).

Die Annahme einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit iSd. § 2 Abs. 1 Satz 3 UStG setzt **drei Merkmale** voraus:

- die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit,
- die Nachhaltigkeit dieser Tätigkeit,
- die Absicht, mit dieser Tätigkeit Einnahmen zu erzielen.

5.2 Tätigkeit im wirtschaftlichen Sinne als Voraussetzung der Unternehmereigenschaft

5.2.1 Leistungen im wirtschaftlichen Sinne

Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit muss in Leistungen iSd. UStG bestehen oder auf ein künftiges Erbringen von Leistungen gerichtet sein. Es muss sich dabei um **Leistungen im wirtschaftlichen Sinne** handeln (Abschn. 2.3 Abs. 1 Satz 2 UStAE).

Es müssen Leistungen erbracht werden, bei denen ein über die reine Entgeltentrichtung hinausgehendes, eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgt wird (Abschn. 1.1 Abs. 3 Satz 2 UStAE). Betätigungen, die nur **Leistungen im Rechtssinne**, nicht aber zugleich auch Leistungen im wirtschaftlichen Sinne darstellen, machen den Handelnden nicht zum Unternehmer.

Nach Abschn. 2.3 Abs. 1 Satz 5 UStAE begründet die **Unterhaltung von Giro-, Bauspar- und Sparkonten** als bloße Leistung im Rechtssinne nicht die Unternehmereigenschaft einer natürlichen Person.

5.2.2 Holdinggesellschaften

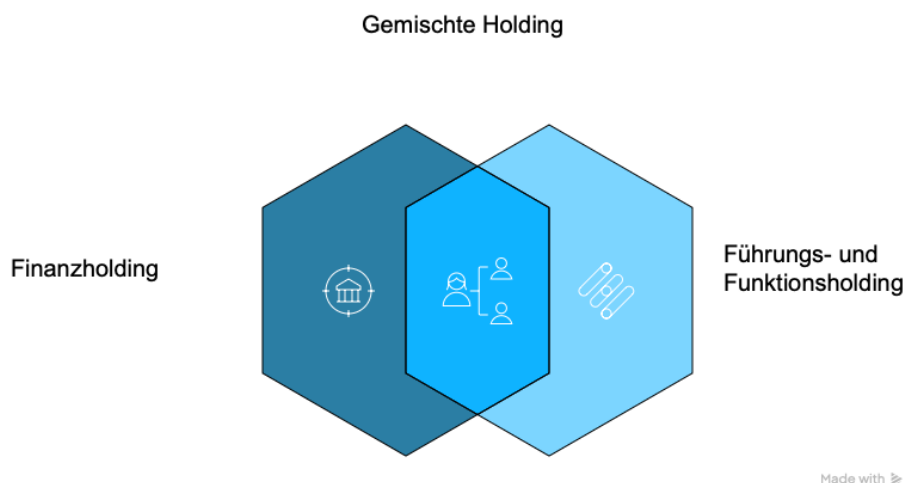


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Holdinggesellschaften als Unternehmer – v10268

Verneint wird die Unternehmereigenschaft von Unternehmen, die nur Geschäftsführungs- oder Holdingfunktionen haben, deren Tätigkeit auf die Ausgabe eigener Anteile beschränkt ist. Eine Holding, deren Zweck sich also auf das Halten und Verwalten gesellschaftsrechtlicher Beteiligungen beschränkt und die damit keine Leistungen gegen Entgelt im wirtschaftlichen Sinn erbringt (sog. **Finanzholding**), ist nicht Unternehmer iSv. § 2 UStG (Abschn. 2.3 Abs. 3 Satz 2 UStAE). Demgegenüber ist eine Holding, die im Sinne einer einheitlichen Leitung aktiv in das laufende Tagesgeschäft ihrer Tochtergesellschaften eingreift (sog. **Führungs- und Funktionsholding**), unternehmerisch tätig (Abschn. 2.3 Abs. 3 Satz 3 UStAE). Zur **gemischten Holding**, die sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig ist, vgl. Abschn. 2.3 Abs. 3 Satz 4 UStAE.

Halten und Verwalten von Beteiligungen



Eine Führungs- und Funktionsholding kann Vorsteuerbeträge, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen an einer Tochtergesellschaft stehen, als **Vorsteuer** abziehen, soweit sie nicht umsatzsteuerfreie Ausschlussumsätze tätigt. Das gilt nicht nur für Leistungsbezüge, die in direktem Zusammenhang mit ihren Leistungen an die Tochtergesellschaften stehen, sondern auch für Gemeinkosten (Abschn. 15.22 UStAE).

5.2.3 Nichtunternehmerische Tätigkeiten

Von der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit sind die nichtunternehmerischen Tätigkeiten zu unterscheiden (Abschn. 2.3 Abs. 1a UStAE). Diese Tätigkeiten umfassen

- die **nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren Sinn**, zB.
 - unentgeltliche Tätigkeiten eines Vereins, die aus ideellen Vereinszwecken verfolgt werden,
 - hoheitliche Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts,
 - bloßes Erwerben, Halten und Veräußern von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen,
- die **unternehmensfremden Tätigkeiten**, zB. Entnahmen für den privaten Bedarf des Unternehmers.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 war zu erkennen, dass das bloße Halten von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen (GmbH-Anteile) keine unternehmerische Tätigkeit ist (Abschn. 2.3 Abs. 2 UStAE), ein aktives Eingreifen in die Verwaltung einer Gesellschaft durch die Geschäftsführungstätigkeit jedoch zu einem steuerbaren Umsatz führt.

5.3 Nachhaltigkeit

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit ist auf das **Gesamtbild der Verhältnisse** abzustellen. Für dieses Gesamtbild sind Merkmale zu suchen, die einerseits für und andererseits gegen die Nachhaltigkeit sprechen. Alle diese Merkmale sind im Einzelfall zu gewichten. Sie können bei einer Gesamtbetrachtung von erhöhter oder von geringerer Bedeutung sein.

Kriterien, die **für die Nachhaltigkeit** der zu beurteilenden Tätigkeit sprechen können, sind vor allem (Abschn. 2.3 Abs. 5 Satz 4 UStAE):



So hat der BFH mit Urteil v. 12.8.2015, XI R 43/13, entschieden, dass derjenige, der planmäßig und mit erheblichem Organisationsaufwand **140 fremde Pelzmäntel** in eigenem Namen **über eBay verkauft**, eine unternehmerische Tätigkeit ausübt. Mit Urteil vom 12.5.2022, V R 19/20, hat er diese Sichtweise allgemein für eine Handelstätigkeit über eBay bekräftigt.

6. Erzielung von Einnahmen

Die nachhaltige Tätigkeit muss auf die **Erzielung von Einnahmen** gerichtet sein. Darunter ist eine Tätigkeit iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG zu verstehen.



HINWEIS

Das UStG stellt nicht auf Gewinne, sondern auf Einnahmen ab, so dass die Unternehmereigenschaft nach § 2 Abs. 1 UStG zu bejahen ist, wenn ertragsteuerlich Liebhaberei vorliegt (Abschn. 2.3 Abs. 8 Satz 2 UStAE). Mit der Umsatzsteuer als Verbrauchsteuer soll der Aufwand des Leistungsempfängers, der beim Leistenden der Einnahme entspricht, besteuert werden.

Die Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen muss entweder eine **Leistung** im Rahmen eines **umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs** sein (Abschn. 2.3 Abs. 8 Satz 3 UStAE) oder eine vorbereitende Tätigkeit, die zwar nicht Leistung iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG ist, aber auf ein späteres Leistungsverhalten gegen Entgelt abzielt (Abschn. 2.6 Abs. 1 UStAE). Es genügt zur Annahme einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit iSd. UStG, dass jemand seine Leistung von der Erstattung der Selbstkosten oder auch nur eines Teils der Selbstkosten abhängig macht.

7. Beginn und Ende der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit

7.1 Beginn der Unternehmertätigkeit



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beginn der Unternehmereigenschaft – v10258

7.1.1 Unternehmereigenschaft aufgrund von Vorbereitungshandlungen

Schon nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 UStG **beginnt** die unternehmerische Tätigkeit bereits mit der ersten, nach außen erkennbaren und auf die Ausführung entgeltlicher Leistungen gerichteten Handlung (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Vorsteuern aus Leistungsbezügen zur Vorbereitung entgeltlicher Leistungen sind bereits in dem Voranmeldungszeitraum (§ 16 Abs. 2 Satz 1 UStG) abziehbar, in welchem dem „Unternehmer“ die Rechnung mit der gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer zugeht, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG vorliegen.

► Fallbeispiel:

Annamaria Schnell bereitet sich auf die Steuerberaterprüfung vor, deren schriftlichen Teil sie im Oktober ablegen will. Sie hat nachweisbar die Absicht, sich nach bestandener Prüfung mit einer eigenen Steuerkanzlei selbständig zu machen. Frau Schnell hat aus dem Kauf eines Pkw und eines PC den Vorsteuerabzug vorgenommen.

Nach bestandener mündlicher Prüfung wird sie zur Steuerberaterin bestellt und eröffnet umgehend ihre Steuerberatungskanzlei.

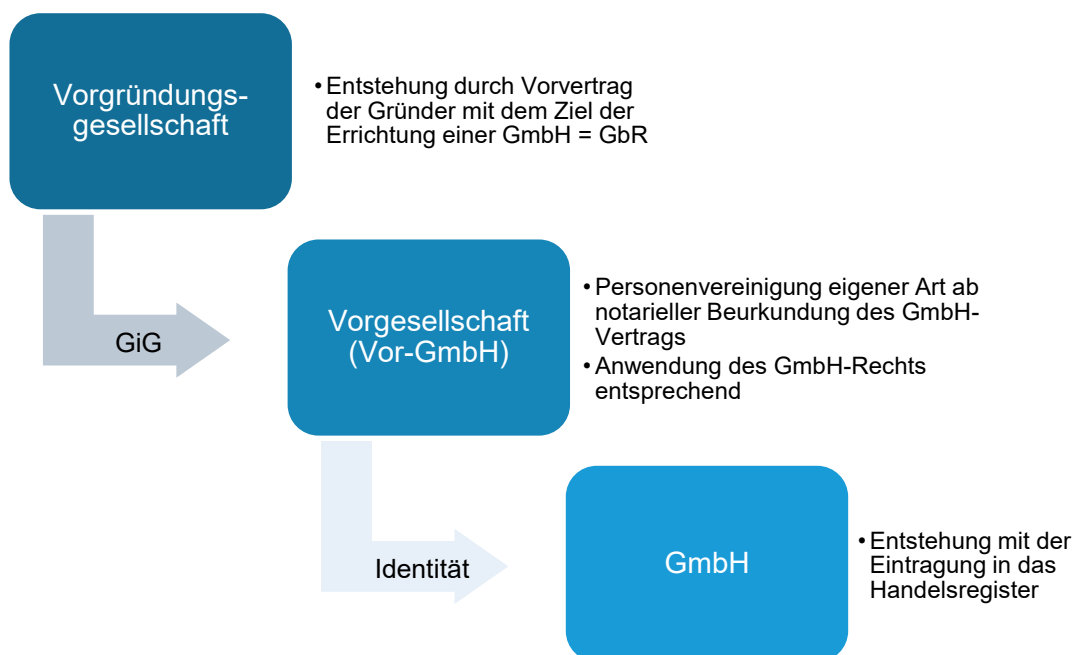
► Lösung:

Die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung und der Kauf der später für ihre freiberufliche Tätigkeit zu verwendenden Gegenstände stellen die ersten nach außen erkennbaren, auf eine nachfolgende Unternehmertätigkeit gerichteten Handlungen dar. Bereits zu diesem Zeitpunkt beginnt die Unternehmereigenschaft der Annamaria Schnell. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG steht ihr der Vorsteuerabzug zu.

Wurde ein Unternehmer aufgrund von Vorbereitungshandlungen bereits zum Unternehmer und stellt er seine Tätigkeit wieder ein, bevor es zu einem Umsatz gekommen war bzw. nimmt er seine Tätigkeit tatsächlich nie auf (sog. **erfolgloser Unternehmer**), bleibt ihm der Vorsteuerabzug dennoch bestehen (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 2, 3 UStAE).

7.1.2 Beginn der Unternehmereigenschaft einer Kapitalgesellschaft

Für die Begründung der Unternehmereigenschaft einer Kapitalgesellschaft ist nicht der zivilrechtliche Entstehungszeitpunkt der Gesellschaft, sondern allein das Erfüllen der Voraussetzungen des § 2 UStG maßgebend. Dabei ist zwischen der sog. **Vorgründungsgesellschaft**, der **Vorgesellschaft** und der durch Eintragung ins Handelsregister entstehenden **Kapitalgesellschaft** zu unterscheiden. Die GmbH wird erst mit der Eintragung in das Handelsregister als juristische Person existent. Vor der Eintragung besteht die Gesellschaft als solche nicht (§ 11 Abs. 1 GmbHG). Die Eintragung ist also wie bei anderen juristischen Personen rechtsbegründend (konstitutiv). Die Gründung der GmbH erfolgt daher in mehreren Schritten



7.1.2.1 Vorgründungsgesellschaft

Mit dem Entschluss, eine Kapitalgesellschaft (zB. GmbH oder AG) zu gründen, entsteht zwischen den Gründern eine Vorgründungsgesellschaft, die **bis zum Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags** besteht. Sie ist als Personengesellschaft der Gründer (in der Form einer GbR oder OHG) ein eigenständiges Rechtssubjekt. Sie ist in zivilrechtlicher wie auch umsatzsteuerlicher Sicht weder mit der Vorgesellschaft noch mit der eingetragenen Kapitalgesellschaft identisch. Eine Vorgründungsgesellschaft, die allein mit dem Ziel der Gründung einer Kapitalgesellschaft errichtet wurde und die die Veräußerung der von ihr erworbenen **Vermögensgegenstände** auf die noch zu gründende Kapitalgesellschaft bewirkt, ist grds. **zum Vorsteuerabzug berechtigt**. Die Vorgründungsgesellschaft führt zwar selbst keine besteuerten Umsätze aus, weil ihr einziger Ausgangsumsatz – die Übertragung ihres Gesamtvermögens auf die Kapitalgesellschaft – als Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbar ist. Der Vorgründungsgesellschaft werden aber die beabsichtigten Umsätze der Kapitalgesellschaft zugerechnet. Beabsichtigt die Kapitalgesellschaft, sog. Abzugsumsätze zu erbringen, steht der Vorgründungsgesellschaft der Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen zu. Sowohl Rechtsprechung als auch Finanzverwaltung (Abschn. 15.2b Abs. 4 UStAE) fordern jedoch, dass es sich hierbei um Investitionsumsätze handelt, die im Wege der Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG auf die

GmbH übergehen. Damit sind Vorsteuern auf Leistungen, die nicht auf die GmbH übertragen werden können, wie beispielsweise Beratungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Gründung auf Ebene der Vorgründungsgesellschaft anfallen, vom Vorsteuerabzug regelmäßig ausgeschlossen.



HINWEIS

Die gleichen Grundsätze greifen, wenn ein einzelner Gesellschafter beabsichtigt, eine GmbH zu gründen und Vorsteuern bei ihm vor Gründung der GmbH anfallen.

7.1.2.2 Vorgesellschaft

Die Vorgesellschaft besteht im Zeitraum zwischen dem Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags und der Eintragung der Kapitalgesellschaft ins Handelsregister. Nach der ständigen Rspr. des BFH ist diese Vorgesellschaft nach denselben steuerlichen Grundsätzen zu behandeln wie die nachfolgende, eingetragene Kapitalgesellschaft. Die im Zivilrecht entwickelte **Identitätstheorie** wird uneingeschränkt ins Steuerrecht übernommen. Mit Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags erlangt die Vorgesellschaft die **Unternehmereigenschaft**, die Vorgesellschaft führt damit eine nach außen erkennbare, auf eine Unternehmertätigkeit gerichtete Handlung aus. Sie beabsichtigt ernsthaft, später entgeltliche Leistungen auszuführen, und kann die Ernsthaftigkeit dieser Absicht durch objektive Merkmale nachweisen oder glaubhaft machen (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 1 UStAE).

Die an die Vorgesellschaft erbrachten Leistungen werden so behandelt, als seien sie an die ins Handelsregister eingetragene Kapitalgesellschaft bewirkt worden. Der Vorgesellschaft steht daher der **Vorsteuerabzug** aus diesen Leistungsbezügen zu, wenn auch die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG erfüllt sind. Umsatzsteuerbeträge für Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gründung der Kapitalgesellschaft anfallen, sind bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteuern durch die Kapitalgesellschaft abziehbar. Die Leistungsbezüge sind nicht den nicht steuerbaren Umsätzen aus der Gewährung der Gesellschaftsrechte, sondern den künftigen Umsätzen ihrer beabsichtigten gewerblichen oder beruflichen Betätigung zuzurechnen.

Auch die Umsatzsteuer, die der **Notar** für die Protokollierung des Gesellschaftsvertrags in Rechnung stellt, kann von der im Entstehen begriffenen Kapitalgesellschaft als **Vorsteuer** abgezogen werden. Es handelt sich um eine Leistung, die der Kapitalgesellschaft die **Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit** ermöglicht.

► Fallbeispiel:

Max Gründlich und Theo Vogl, die beide als Ingenieure tätig sind, planen, ein Charterunternehmen für Motorsegler in der Rechtsform einer GmbH zu gründen. Sie beauftragen im Frühjahr ein Marktforschungsunternehmen, in einer Marktanalyse die geschäftlichen Aussichten ihres Projekts zu untersuchen. Das Ergebnis der Marktanalyse, für die den Herren Gründlich und Vogl am 20.9. ein Betrag von 20.000 € zzgl. 3.800 € USt in Rechnung gestellt wird, ist vorsichtig positiv. Daraufhin gründen sie am 15.10. durch notariellen Vertrag die „Ottobrunner Motorsegler Chartergesellschaft mbH“, die der Notar zur Eintragung ins Handelsregister anmeldet. Die GmbH soll im Frühjahr des Folgejahres den Geschäftsbetrieb aufnehmen. In USt-Voranmeldungen für September und Oktober zieht die GmbH die 3.800 € USt und weitere 1.900 € USt, die der Notar für die Beurkundung des GmbH-Vertrags berechnet hat, als Vorsteuer ab.



► **Lösung:**

Die Vorgründungsgesellschaft Gründlich + Vogl ist nicht identisch mit der Vor-GmbH (Gründungsgesellschaft), die zwischen dem Zustandekommen des GmbH-Vertrags und der Eintragung ins Handelsregister besteht. Der Vorgründungsgesellschaft steht das Recht auf Vorsteuerabzug nicht zu, da sie lediglich Beratungsleistungen bezieht, die nicht auf die spätere GmbH übertragbar sind (Abschn. 15.2b Abs. 4 UStG). Die Vorsteuer iHv. 3.800 € kann daher weder von der Vorgründungsgesellschaft noch von der (Vor-)GmbH abgezogen werden. Hingegen kann die (Vor-)GmbH die für die Beurkundung der Satzung berechnete USt iHv. 1.900 € als Vorsteuer abziehen.

7.1.3 Beginn der Unternehmereigenschaft einer Personengesellschaft

Im Unterschied zur Kapitalgesellschaft entsteht die Personengesellschaft bereits mit dem Zustandekommen des Gesellschaftsvertrags; die Eintragung in das Handelsregister/Partnerschaftsregister ist nicht konstitutiv. Die Personengesellschaft wird daher Unternehmer mit dem ersten nach außen erkennbaren, auf eine Unternehmertätigkeit gerichteten Tätigwerden, wenn die spätere Ausführung entgeltlicher Leistungen beabsichtigt ist und die Ernsthaftigkeit dieser Absicht durch objektive Merkmale nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 1 UStAE).

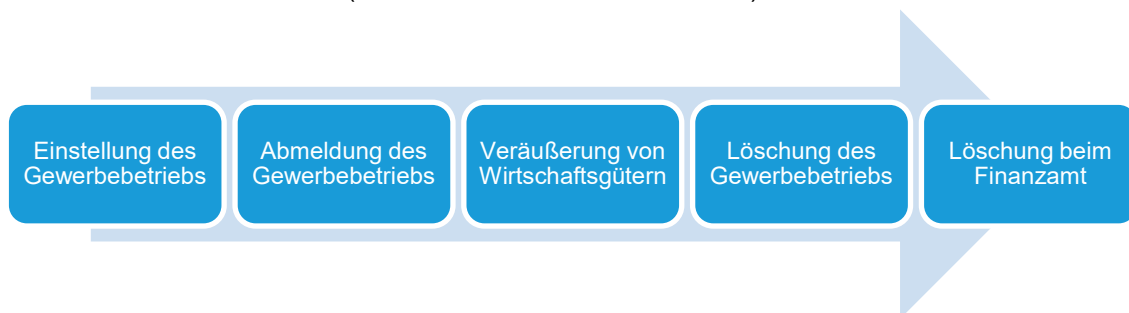
7.2 Ende der Unternehmereigenschaft



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ende der Unternehmereigenschaft – v10263

Nach Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 1 UStAE endet die Unternehmereigenschaft mit dem letzten Tätigwerden des Unternehmers, das auch nach der Einstellung oder Abmeldung des Gewerbebetriebs liegen kann. So gehören insb. die spätere Veräußerung von Gegenständen des Betriebsvermögens oder die nachträgliche Vereinnahmung von Entgelten noch zur Unternehmertätigkeit (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 4 UStAE). Nach **Beendigung der unternehmerischen Betätigung** können Unternehmer bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen Vorsteuern für Leistungen, die sie in der **Zeit ihrer Unternehmertätigkeit** in Anspruch genommen haben und die ihnen erst später in Rechnung gestellt werden, als abziehbar geltend machen, so zB. USt-Beträge, die für die Erstellung des Jahresabschlusses des inzwischen eingestellten Unternehmens berechnet werden. Unternehmen und Unternehmereigenschaft erlöschen erst, wenn der Unternehmer **alle Rechtsbeziehungen abgewickelt** hat, die mit dem (aufgegebenen) Betrieb in Zusammenhang stehen; zu diesen Rechtsbeziehungen gehört auch das Rechtsverhältnis zwischen dem Unternehmer und dem Finanzamt (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 6 UStAE).



Die zivil- und handelsrechtlichen Bestimmungen zur **Auflösung von Personengesellschaften** (zB. § 131 HGB für die OHG) führen **nicht** zum **Verlust der Unternehmereigenschaft**. Diese bleibt während des Liquidationsstadiums erhalten.

Die Auflösung der Gesellschaft ändert nur ihren Zweck, der sich nun auf die Abwicklung, insb. auf die Auseinandersetzung des Gesamthandsvermögens richtet. Umsatzsteuerlich besteht eine Gesellschaft als Unternehmer so lange fort, bis alle gemeinsamen Rechtsbeziehungen, zu denen auch das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Steuergläubiger (Fiskus) gehören, unter den Gesellschaftern abgewickelt sind (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 6 UStAE).

Die Eröffnung des **Insolvenzverfahrens** führt noch nicht zum Ende der Unternehmertätigkeit. Die vom Insolvenzverwalter bewirkten Umsätze sind dem Gemeinschuldner als Unternehmer zuzurechnen (Abschn. 2.1 Abs. 7 Satz 1 UStAE).

Auch eine Kapitalgesellschaft, die mit der Löschung im Handelsregister ihre Rechtsfähigkeit verliert, besteht als Unternehmer grundsätzlich so lange fort, bis alle Rechtsbeziehungen der Gesellschaft abgewickelt sind; hierzu gehört auch das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Finanzamt. Dementsprechend kann eine **aufgelöste GmbH** auch noch nach ihrer Löschung im Handelsregister Umsätze im Rahmen ihres Unternehmens ausführen (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 7, 8 UStAE).

Die Unternehmereigenschaft kann zB. auch fortbestehen, wenn zwar ein bisher als Einzelunternehmen betriebener Handwerksbetrieb in eine GmbH gegen Gewährung von Anteilen eingebracht wird und das Betriebsgrundstück nachfolgend der GmbH verpachtet wird (so geprüft in der Steuerberaterprüfung 2016). Der Unternehmensteil „Handwerksbetrieb“ scheidet dann zwar zunächst aus dem Unternehmen aus, die Unternehmereigenschaft und damit auch das Unternehmen bestehen aber aufgrund der Verpachtung des Betriebsgrundstücks als „Verpachtungsbetrieb“ fort. Liegen zudem die Voraussetzungen einer Organschaft zwischen dem bisherigen Betriebsinhaber und der neu gegründeten GmbH vor, verbleibt auch der Handwerksbetrieb durch die Eingliederung des Unternehmens der GmbH in dasjenige des Organträgers (bisheriger Betriebsinhaber) in dessen Unternehmen.

8. Das Unternehmen

8.1 Begriff und Bedeutung

Nach **§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG** umfasst das Unternehmen die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers (**Grundsatz der Unternehmenseinheit**). Ein **Unternehmer** kann **nur ein Unternehmen** haben. Dem Unternehmen einer natürlichen Person, einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft sind alle Betriebe, Betriebsstätten, Zweigniederlassungen und dgl. zuzuordnen. Es ist ohne Bedeutung, ob sie im Einzelfall örtlich weit auseinanderliegen, verschiedenen Wirtschaftszweigen angehören, dem Unternehmer selbst gehören oder nur gepachtet sind, unter verschiedenen Firmenbezeichnungen nach außen in Erscheinung treten oder organisatorisch oder wirtschaftlich für sich existieren.

In der Steuerberaterprüfung müssen Sie oftmals auch kurz zur Unternehmereigenschaft und zum Unternehmensumfang Stellung nehmen. Achten Sie hierbei insbesondere auf die nachfolgenden Fälle der **Unternehmenseinheiten** in § 2 Abs. 1–3 UStG:

- Eine natürliche Person, eine Personengesellschaft oder eine juristische Person unterhält **mehrere Betriebe** (Abschn. 2.7 Abs. 1 UStAE). Die Gesamtheit aller Betriebe bildet jeweils das Unternehmen der natürlichen Person, der Personenvereinigung oder der juristischen Person.

► **Beispiel:**

Ein selbstständiger Rechtsanwalt fährt ebenfalls selbstständig Taxi. Taxiunternehmen und Rechtsanwaltskanzlei bilden ein einheitliches Unternehmen.

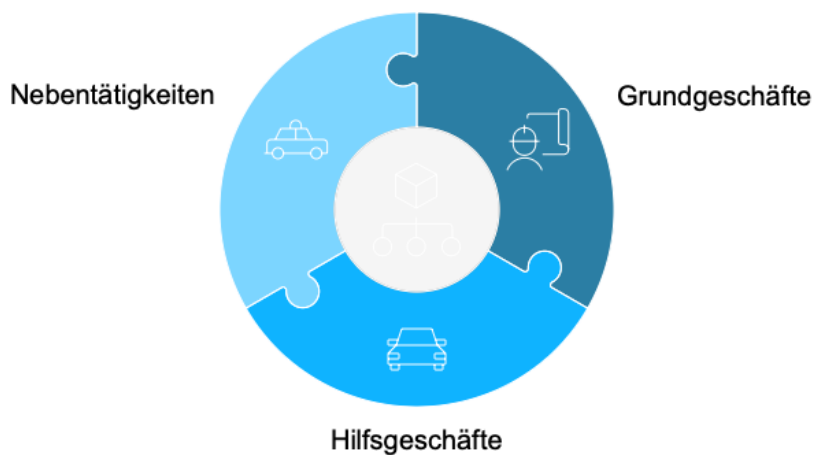
- Eine oder mehrere juristische Personen sind durch **Organschaft** einem Unternehmen untergeordnet. **Unternehmer** ist nur der **Organträger**; die Organgesellschaften stellen unselbständige Teile des Unternehmens des Organträgers dar.

► **Beispiel:**

Die Erzeugnisse der Maschinenfabrik Atlas AG werden von der Atlas Vertriebsgesellschaft mbH vertrieben, deren Anteile die AG zu 100 % besitzt und deren Alleingeschäftsführer leitender Mitarbeiter bei der AG ist. Unternehmer ist der Organträger, die Fa. Atlas AG; die Organgesellschaft Atlas Vertriebsgesellschaft mbH ist ein unselbständiger Teil des Unternehmens der AG (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG).

8.2 Der unternehmerische und der nichtunternehmerische Tätigkeitsbereich

Zu dem die gesamte gewerbliche und berufliche Tätigkeit des Unternehmers umfassenden Unternehmen rechnen neben den Leistungen, die den eigentlichen Zweck der unternehmerischen Betätigung ausmachen (**Grundgeschäfte**), auch die sog. **Hilfsgeschäfte** und **Nebentätigkeiten** (Abschn. 2.7 Abs. 2 UStAE). Auf die Nachhaltigkeit bei der Ausführung von Hilfsgeschäften oder Nebentätigkeiten kommt es nicht an.



► **Fallbeispiel:**

Ein freiberuflich tätiger Rechtsanwalt veräußert seinen fast ausschließlich für Zwecke seiner Anwaltstätigkeit genutzten Pkw; außerdem veräußert er, wegen Umstellung seiner IT-Anlage, bisher genutzte Hardware. Der Anwalt veröffentlicht gelegentlich Aufsätze in der Zeitschrift NWB. Er ist Mitglied im Prüfungsausschuss der Rechtsanwaltskammer, die die Prüfungen für Rechtsanwaltsfachangestellte abnimmt (ehrenamtliche Tätigkeit gegen geringfügige Aufwandsentschädigung).

► **Lösung:**

Neben den mit der anwaltlichen Tätigkeit ausgeführten Grundgeschäften rechnen zur unternehmerischen Betätigung auch die Hilfsgeschäfte und Nebentätigkeiten, die seine Haupttätigkeit, der Betrieb seiner Anwaltskanzlei, mit sich bringt. Als Nebentätigkeiten sind die fachschriftstellerische Tätigkeit und die ehrenamtliche Tätigkeit in der Standesorganisation, als Hilfsgeschäfte der Verkauf des gebrauchten betrieblichen Pkw und der Anlagegegenstände anzusehen.

9. Der Verein als Unternehmer

Der **EuGH** hat mit seinem für die Vereinsbesteuerung wegweisenden Urteil vom 21.3.2002, Rs. C-174/00 – *Kennemer Golf & Country Club*, DB 2002, S. 1538 = UR 2002, S. 320, die **Unterscheidung in Abschn. 1.4 Abs. 1 UStAE** zwischen echten Mitgliedsbeiträgen und Entgelt für Leistungen, die nur den Sonderbelangen von Mitgliedern dienen (unechte Mitgliedsbeiträge), **verworfen**. Die Finanzverwaltung hat sich zur Anwendbarkeit der Grundsätze der EuGH-Entscheidung nach über 15 Jahren immer noch nicht geäußert, so dass die in Abschn. 1.4 Abs. 1 UStAE und Abschn. 2.10 UStAE dargestellten Grundsätze weiterhin anwendbar bleiben, sofern sie für den betroffenen Verein günstiger sind. Vereine (zB. Berufsverbände), für die hingegen die EuGH-Entscheidung günstiger ist, können sich auf den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts in der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie berufen.



PRÜFUNGSTIPP

Aufgrund dieser ungeklärten Gemengelage ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Klausurersteller einen Verein zum Gegenstand der Umsatzsteuerteilaufgabe der Steuerberaterprüfung macht, doch recht gering. Vor diesem Hintergrund verzichten wir an dieser Stelle auf weitere Ausführungen zum Thema „Der Verein als Unternehmer“.

10. Kleinunternehmerschaft



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2020 waren die Voraussetzungen der Kleinunternehmerschaft und die Folgen eines Wechsels der Besteuerungsform zu prüfen. In den Allgemeinen Hinweisen findet sich zudem meist der Hinweis, dass auf die Anwendung der Regelung nicht verzichtet wurde.

Unternehmer, die die Voraussetzungen der Kleinunternehmerschaft in § 19 UStG erfüllen, bewirken steuerfreie Umsätze. Die Regelung findet automatisch Anwendung, wenn die Voraussetzungen der Unternehmereigenschaft grds. erfüllt sind, der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000 € nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 100.000 € nicht übersteigt. Mit dem ersten Umsatz, mit dem die Jahresgesamtumsatzgrenze überschritten wird, wird der Kleinunternehmer zum Regelversteuerer.

Die Steuerbefreiung findet automatisch Anwendung, sofern die Voraussetzungen des § 19 UStG erfüllt sind. Der Unternehmer kann jedoch auf die Steuerbefreiung verzichten (§ 19 Abs. 3 UStG). Hintergrund ist hier meist die Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen, die bei Anwendung der Kleinunternehmerregelung ausgeschlossen wäre (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG). Weitere Auswirkungen ergeben sich zudem insbesondere bei der Option des § 9 UStG, der Einstufung als Schwellenerwerber nach § 1a Abs. 3 UStG sowie der Notwendigkeit einer Vorsteuerberichtigung bei Wechsel der Besteuerungsform nach § 15a Abs. 7 UStG.



HINWEIS

Die Regelung wurde mit Wirkung zum 1.1.2025 neu gefasst.

Eine genauere Darstellung der Regelung erhalten Sie durch einen Schwerpunktlehrbrief im Rahmen des Klausurenkurses.



II. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Franz Ferstl betreibt in Rosenheim ein alteingesessenes Trachtenfachgeschäft. Ferstl verkauft Trachten aller Art, historische und moderne, vom Dirndl bis zur Lederhose. Angegliedert ist eine eigene Schneiderei, in der der Großteil der Trachten gefertigt wird.

Das Geschäftshaus, das im Alleineigentum von Franz Ferstl steht, befindet sich in Rosenheim, Marktplatz 12.

Franz Ferstl hat das traditionsreiche Trachtengeschäft seines Vaters übernommen und es im Laufe der Jahre zu einem führenden Unternehmen in seiner Branche ausgebaut. Zum 1.1.01 gründete Ferstl die Trachten Ferstl GmbH mit Sitz in Rosenheim. Alleiniger Gesellschafter war Franz Ferstl, der auch – ausgestattet mit einem ordnungsgemäßen Arbeitsvertrag – zum alleinigen Geschäftsführer bestimmt wurde. In Zusammenhang mit der Gründung stellte der Notar der GmbH 2.000 € zuzüglich 19 % USt 380 € am 20.1.01 in Rechnung.

Franz Ferstl brachte sein bisheriges Einzelunternehmen mit allen Aktiva und Passiva, mit Ausnahme des Geschäftsgebäudes Marktplatz 12, ein. Allerdings vermietet er die bisher vom Einzelunternehmen genutzten Räume für zunächst 15 Jahre mit Verlängerungsoption an die GmbH.

Nachdem seine Tochter Therese Ferstl das Geschäft von Grund auf gelernt hatte, übertrug Franz Ferstl ihr zum 1.8.01 60 % der Anteile an der GmbH. Darüber hinaus zog er sich als Geschäftsführer zurück. Alleinige angestellte Geschäftsführerin war ab 1.8.01 Therese Ferstl. Der Notar berechnete Franz für die Beurkundung der Anteilsübertragung am 10.8.01 1.000 € zuzüglich 19 % USt 190 €.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Franz Ferstl und die Trachten Ferstl GmbH im Besteuerungszeitraum 01. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht bzw. zu berichtigen ist und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Gehen Sie auch kurz auf die Unternehmereigenschaft und den Umfang des Unternehmens von Franz Ferstl und der Trachten Ferstl GmbH ein.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 04 – v13122

	Punkte	
	Soll	Ist
I. Unternehmereigenschaft und Umfang des Unternehmens		
Franz Ferstl ist Unternehmer iSv. § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG. Zum Umfang seines Unternehmens (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG) zählen: - das Trachtenfachgeschäft aufgrund der Stellung als Organträger bis 31.7.01 - die Vermietung des Gebäudes ab 1.8.01. (bis 31.7. Innenumsatz) Nicht dazu zählt die Geschäftsführung für die GmbH, da diese nicht selbständig als Arbeitnehmer (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG) ausgeübt wird.	1	
Die Trachten Ferstl GmbH ist für den Gründungsvorgang Unternehmerin iSv. § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG. Nach dem Gründungsvorgang besteht ein Organisationsverhältnis mit Franz Ferstl (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG, s. unten II.1.), so dass sie ihre Selbstständigkeit verliert und keine Unternehmerin mehr ist. Nach Beendigung der Organschaft ab 1.8.01 ist die GmbH selbstständig (§ 2 Abs. 1 Satz 1 UStG), zum Umfang ihres Unternehmens zählt das Trachtenfachgeschäft (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG).	1	
II. Geschäftsvorfälle		
Gründungsvorgang Die GmbH erbringt mit der Ausgabe der Anteile keinen steuerbaren Umsatz (Abschn. 1.6 Abs. 2 Satz 2 UStAE).¹ Franz Ferstl bringt sein Einzelunternehmen ein. Dies stellt eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG) dar. Die langfristige Vermietung (15 Jahre mit Verlängerungsoption) sichert die dauerhafte Fortführung (Abschn. 1.5 Abs. 3 Satz 2 UStAE) der Unternehmenstätigkeit.	1	
Aus der Notarrechnung kann die GmbH einen Vorsteuerabzug iHv. 380 € mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung Januar 01 vornehmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Abschn. 15.21 Abs. 3, 4 UStAE).	2	
Organschaft ab 1.1. bis 31.7.01 (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG): Organträger ist Franz Ferstl, er ist Unternehmer (so.), Organgesellschaft ist die GmbH als juristische Person des Privatrechts	1	

¹ Laut Aufgabenstellung müssen Sie nur die „gesetzlichen Bestimmungen“ zitieren. Dazu zählt der UStAE nicht. Die UStAE-Fundstellen dienen hier nur zu Ihrer Information und zur Nacharbeitung der Lösung.



Finanzielle Eingliederung: Franz Ferstl ist alleiniger Gesellschafter der GmbH, so dass diese in sein Unternehmen finanziell eingegliedert ist (Abschn. 2.8 Abs. 5 UStAE). Wirtschaftliche Eingliederung: Franz Ferstl überlässt der GmbH langfristig das Betriebsgrundstück als wesentliche Betriebsgrundlage, so dass nicht unwesentliche Leistungsbeziehungen zwischen ihm und der GmbH bestehen. Zudem liegt ertragsteuerlich eine Betriebsaufspaltung vor. Damit ist eine wirtschaftliche Eingliederung gegeben (Abschn. 2.8 Abs. 6b UStAE). Die GmbH-Geschäftsanteile zählen zum Unternehmensvermögen von Franz Ferstl (Abschn. 2.3 Abs. 3 Satz 5 Nr. 2 UStAE).	1	
Organisatorische Eingliederung: Da Franz Ferstl alleiniger Geschäftsführer der GmbH ist, liegt eine Personalunion in der Geschäftsführung vor (Abschn. 2.8 Abs. 8 UStAE), so dass die organisatorische Eingliederung gegeben ist.		
Folgen: Die GmbH ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht selbständig tätig, Unternehmer ist Franz Ferstl. Die Umsatzsteuererklärungen sind von Franz Ferstl abzugeben. Die Umsätze zwischen Franz Ferstl und der GmbH sind nicht steuerbare Innenumsätze (Abschn. 2.7 Abs. 1 UStAE).	1	
Übertragung der Anteile auf Therese Ferstl: Die unentgeltliche Übertragung der Anteile an Therese Ferstl stellt eine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG dar. Nach § 3a Abs. 1 Satz 1 UStG (nichtunternehmerisches Halten der Anteile durch Therese ohne unternehmerische Tätigkeit, Abschn. 2.3 Abs. 2 Satz 1 UStAE) liegt deren Ort im Inland. Die Übertragung ist steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), aber nach § 4 Nr. 8 Buchst. f UStG steuerfrei. Aus der Notarrechnung steht Franz Ferstl grundsätzlich der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG zu. Jedoch ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG iVm. § 4 Nr. 8 Buchst. f UStG ausgeschlossen (Abschn. 15.22 Abs. 2 Satz 5 UStAE).	1	
Durch die Übertragung von 60 % der Anteile auf Therese Ferstl entfällt die finanzielle Eingliederung in das Unternehmen von Franz Ferstl. Durch die Übernahme der Geschäftsführertätigkeit durch Therese Ferstl liegt auch keine organisatorische Eingliederung mehr vor. Das Organschaftsverhältnis endet daher zum 31.7.01. Ab dem 1.8.01 ist die GmbH selbstständige Unternehmerin.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	10	